

٤٩: ١٤٤٠ هـ
السفوي

الفصل الثاني

مفهوم النكاح، وأحكامه

وفي ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ماهية النكاح، وحكمه .

المبحث الثاني: أركان عقد النكاح، وشروط كل ركن

المبحث الثالث: الآثار الفقهية المترتبة على عقد

النكاح الصحيح.



وعرفه المالكية بأنه: عقد لحل تمتع بأنثى شبر مخدوم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة لقادر محتاج له أو راج نسلًا^(١).

وعرفه الشافعية بأنه: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو بترجمته^(٢).

وعرفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج^(٣).

هذا؛ والمتأمل في هذه التعريفات السابقة للنكاح يجد أنها جميعها قد نصت على كون النكاح:

عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر.

فهي متقاربة في المعنى، وتؤدي في جملتها إلى أن موضوع عقد النكاح امتلاك المتعة على الوجه المشروع، وإلى أن الغرض منه في عرف الناس، والشرع هو جعل هذه المتعة حلالاً.

(١) بلغة المسالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٣٣٢/٧: ٣٣٤.

(٢) الغرر البهية لأبي زكريا الأنصاري ٨٣/٤، حاشيتا قليوبي وعميرة ٢٠٧/٣.

(٣) المغني لابن قدامة ٣/٧، مطالب أولي النهى للرحبياني ٣/٥، الإنصاف للمرداوي ٤/٨.



وعرفه المالكية بأنه: عقد لحل تمتع بأنثى غير مخزوم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة لقادر محتاج له أو راج نسلًا^(١).

وعرفه الشافعية بأنه: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو بترجمته^(٢).

وعرفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج^(٣).

هذا؛ والمتأمل في هذه التعريفات السابقة للنكاح يجد أنها جميعها قد نصت على كون النكاح:

عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر.

فهي متقاربة في المعنى، وتؤدي في جملتها إلى أن موضوع عقد النكاح امتلاك المتعة على الوجه المشروع، وإلى أن الغرض منه في عرف الناس، والشرع هو جعل هذه المتعة حلالاً.

(١) بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٣٣٢/٧ : ٣٣٤.

(٢) الغرر البهية لأبي زكريا الأنصاري ٨٣/٤، حاشيتا قليوبي وعميرة ٢٠٧/٣.

(٣) المغني لابن قدامة ٣/٧، مطالب أولي النهى للرحبياني ٣/٥، الإنصاف للمرادوي ٤/٨.



المطلب الثاني

الخلاف في حقيقة لفظ النكاح، وما يترتب عليه من آثار

يطلق النكاح في اللغة على التزوج والوطء:

يقال: نَكَحَ فلانٌ امرأةً يَنْكِحُها نِكَاحاً إذا تَزَوَّجَها، وَنَكَحَها يَنْكِحُها باضعها (جامعها) أيضاً .

وقد اختلف الفقهاء في حقيقة لفظ النكاح، وما يراد به إذا أطلق في القرآن الكريم، والسنة النبوية؛ هل يراد به الوطء حقيقة، ويكون مجازاً في العقد، أم العكس، أم يكون مشتركاً وحقيقة في كل منهما؟ وقد جاء هذا الخلاف على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وهو ما ذهب إليه الحنفية في الصحيح، ورجحه ابن عبد السلام وغيره من فقهاء المالكية، والشافعية في وجه، وبعض الحنابلة^(١).

القول الثاني: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهو ما ذهب إليه المالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة على الصحيح^(٢).
القول الثالث: أنه حقيقة في كل من العقد والوطء، وهو رأي عند الحنفية على أنه مشترك لفظي فيهما أو مشترك معنوي فيهما.

(١) البحر الرائق ٨٣/٣، مواهب الجليل ٤٠٣/٣، مغني المحتاج ١٢٣/٣،

الإنصاف ٨/٥٠٦.

(٢) مواهب الجليل ٤٠٣/٣، الخرشي مع العدوي ١٦٤/٣، مغني المحتاج ٣/



وثمره هذا الخلاف تظهر فيما يأتي:

(١) من زنى بامرأة؛ هل تحرم على أصوله وفروعه؟

ذهب فقهاء الحنفية، وهو الأشهر عند الحنابلة إلى أن من زنى بامرأة حرمت على أصوله، وفروعه بناء على أن النكاح حقيقة في الوطء.

وذهب فقهاء الشافعية، وهو المعتمد عند المالكية: إلى أن الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة، فإن من زنى بامرأة له أن يتزوج بفروعها وأصولها، ولأبيه وابنه أن يتزوجها؛ وهذا بناء على أن الوطء لا يسمى نكاحاً، ولا يترتب عليه التحريم بالمصاهرة؛ لأن النكاح حيث أطلق حمل على العقد إلا بقرينة (١).

قال -رحمه الله-: { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } [النساء: ٢٢]، ومعناه: لا تتكحوا من عقد عليها آبائكم، وهو يفيد أن من زنى بها أبوه لا تحرم عليه.

وقال مالك: فأما الزنى، فإنه لا يحرم شيئاً من ذلك؛ لأن الله -رحمه الله- قال: { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } [النساء: ٢٣]، فإنما حرم ما كان تزويجاً، ولم يذكر تحريم الزنى، فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته، فهو بمنزلة التزويج الحلال.

(١) البحر الرائق ٨٣/٣، حاشية ابن عابدين ٥/٣، شرح فتح القدير ١٨٧/٣، مجمع الأنهر ٤٦٦/١، الفواكه الدواني ٢١/٢، مواهب الجليل ٤٠٣/٣، الخرشي مع العدوي ١٦٤/٣، مغني المحتاج ١٢٣/٣، الإنصاف ٥/٨، كشف القناع ٥/٥، المغني ٤٤٥/٦.

وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: " سئل رسول الله - ﷺ -
عن رجل زنى بامرأة ، فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: ﴿ لا يحرم
الحرام الحلال ، إنما يحرم ما كان بنكاح ﴾ " (١).
(٢) من حلف لا ينكح ، ومن علق الطلاق على النكاح ؛ هل
يحنث بالعقد أم بالوطء ؟.

ذهب فقهاء الحنفية إلى أنه لو قال لزوجته: إن نكحتك ، فأنت
طالق ، فإنها تطلق بالوطء ، وكذا لو أبانها قبل الوطء ثم تزوجها تطلق
به لا بالعقد ، بخلاف الأجنبية ، فيتعلق بالعقد ؛ لأن وطنها لما حرم
عليه شرعا كانت الحقيقة مهجورة فتعين المجاز .
وذهب فقهاء الشافعية إلى أنه لو حلف لا ينكح حنث بالعقد لا
بالوطء ، إلا إذا نواه ، وكذا لو علق الطلاق على النكاح (٢).

(١) حديث : ﴿ أن الرسول - ﷺ - سئل عن الرجل يتبع المرأة ﴾ . أورده الهيثمي
في مجمع الزوائد (٤ / ٢٦٨) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه
عثمان بن عبد الرحمن الزهري وهو متروك .
(٢) اللباب في شرح الكتاب ١/ ٢٧٠ ، حاشية ابن عابدين ٣/ ٥ ، شرح فتح
القدير ٣/ ١٨٧ ، مجمع الأنهر ١/ ٤٦٦ ، نهاية المحتاج ٦/ ١٧٤ ، مغني
المحتاج ٣/ ١٢٣ .

المطلب الثالث

مشروعية النكاح، وفوائده

أولاً: مشروعية النكاح، ودليها:

النكاح مشروع بالكتاب، والسنة، والإجماع .

أما الكتاب:

فبقوله -ﷺ-: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَى الْأَلَّا تَعُولُوا} [النساء: ٣].

وقوله -ﷺ-: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور: ٣٢].

وأما السنة:

فبما يلي:

(١) ما روي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: ﴿أن نفراً من

أصحاب النبي -ﷺ- سألوا عن عمله في السر؟ فقال

بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم،

وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه

فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام



وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (١).

(٢) قوله -ﷺ-: ﴿يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة (٢) فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (٣)﴾ (٤).

وأما الإجماع:

فقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح . وفي هذا يقول ابن قدامة المقدسي: " وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع " (٥).

(١) صحيح مسلم ١٠٢٠/٢ كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تأقت نفسه إليه حديث رقم/١٤٠١ .

(٢) الباءة - بالمد -: الجماع . وهو المراد هنا، وقيل: مؤن النكاح، والقائل بالأول رده إلى معنى الثاني؛ إذ التقدير عنده: " من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع لعجزه عنها فعليه بالصوم "، وإنما قدره بذلك؛ لأن من لم يستطع الجماع لعدم شهوته لا يحتاج إلى الصوم لدفعها . ينظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢٠٣/٤ .

(٣) أصل الوجاء: من الوجء وهو: رض الخصيتين بقصد قطع الشهوة، فأراد -ﷺ- أن الصوم يقطع شهوة الجماع كما يقطعها الوجاء . ينظر: لسان العرب لابن منظور مادة (وَجَأ) .

(٤) متفق عليه. ينظر: صحيح البخاري ١٩٥٠/٥ كتاب النكاح باب من لم يستطع الباءة فليصم حديث رقم/٤٧٧٩، صحيح مسلم ١٠١٨/٢ كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تأقت نفسه إليه حديث رقم/١٤٠٠ .

(٥) المغني لابن قدامة المقدسي ٣/٧ .

سبب مشروعية النكاح:

السبب وراء شرعية النكاح: تعلق البقاء المقدر في العلم الأزلي على الوجه الأكمل، وإلا فيمكن بقاء النوع بالوطء على غير الوجه المشروع، لكنه مستلزم للتظالم، والسفك، وضياح الأنساب، بخلافه على الوجه المشروع (١).

ثانياً: مقاصد النكاح، وفوائده:

الزواج في الإسلام له مقاصد عظيمة تحافظ على نظافة، وطهارة المجتمع الإسلامي وتضمن بقاء وسلامة النوع الإنساني؛ وأهم هذه المقاصد ما يلي:

- (١) الزواج بيئة صالحة تؤدي إلى ترابط الأسرة، وتبادل المحبة، وإعفاف النفس، وصيانتها عن الحرام.
- فالزواج في الإسلام نبع يفيض بأسمى الأخلاق، ومدرسة جامعة يتعلم فيها الزوجان أصول المودة والرحمة والحب، وما ينشأ عنها من الغيرة والعزة والوفاء ورعاية المحرمات.
- (٢) الزواج خير وسيلة لإنجاب الأولاد، وتكثير النسل مع المحافظة على الأنساب.
- فينبغي أن تكون الزوجة منجبة، ويعرف ذلك بسلامة بدنها، وبقياسها على مثيلاتها من أخواتها وعماتها وخالاتها.

(١) شرح فتح القدير لابن الهمام ١٨٧/٣، العناية شرح الهداية لأكمل الدين البابرتي ١٨٧/٣.



فقد خطب رجل امرأة عقيماً لا تلد، فقال: يا رسول الله، إني خطبت امرأة ذات حسب، وجمال وانها لا تلد، فنهاه رسول الله - ﷺ -، وقال: ﴿تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة﴾ . والودود: هي المرأة التي تتودد إلى زوجها وتحبب إليه، وتبذل طاقاتها في مرضاته.

وذكر ابن القيم كذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - ﷺ - : "أنه أمر رجلاً عقيماً تزوج امرأة من غير أن يخبرها، أن يخبرها بعقمه ثم يخبرها".

فحكمه - ﷺ - على الزوج بإخبار زوجته وتخبرها، لأن الغرض الأسمى للزواج هو الإتيان، وهو مطلب لكلا الزوجين على السواء، وعدم الإتيان مناف للسكن والرحمة والمودة وعلى ذلك سارت قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلدان الإسلامية.

(٣) الزواج أحسن وسيلة لإرواء الغريزة الجنسية ، وقضاء الوطر مع السلامة من الأمراض .

(٤) في الزواج إشباع لغريزة الأبوة، والأمومة التي تنمو بوجود الأطفال .

(٥) في الزواج تحقيق السكينة بين الزوجين؛ فإن في الزواج سكن ، وطمانينة ، واحتشام ، وإعفاف للزوج والزوجة. وقد اقتضت حكمة الله أن جعل لكل من الذكر والأنثى خواص تقتضي وجوب الزواج بينهما ، لتحصل لهما



السكينة الجسدية والعقلية، ذلك أن القوة الجنسية لكل منهما لا تندفع إلا بهذا التزاوج .

وقد بين الله - ﷻ - ذلك في قوله: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} [الأعراف: ١٨٩]، وقوله - ﷻ -: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: ٢١].

وقد أكد رسول الله - ﷺ - على ما ينال المرأة من سخط الله إذا منعت زوجها من مسها ، في قوله - ﷻ -: ﴿والذي نفسي بيده ! ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، فتأبى عليه ، إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها ﴾ .

وكما أن للزوج الحق في السكينة مع زوجته ، فإن لها الحق في ذلك مما هو مبين في كتب الفقه عن الحقوق المشتركة بين الزوجين^(١).

كما أن للنكاح فوائد كثيرة؛ لعل أهمها:

- (١) دفع غوائل الشهوة .
- (٢) حفظ النسل، وبقاء الخلق إلى يوم القيامة، ولا يحصل ذلك إلا بالنكاح .
- (٣) بقاء الذكر ورفع الدرجات بسبب دعاء الولد الصالح .
- (٤) التنبيه باللذة الفانية على اللذة الدائمة؛ لأنه إذا ذاق هذه اللذة وعلم أن له إذا عمل الخير ما هو أعظم

(١) ينظر : الولاية في النكاح: عوض بن رجا بن فريج العوفي ٥٤/١، رسالة في

الفقه الميسر: صالح بن غانم السدلان ١٠٦/١.



سارع في الخيرات لما هو من جنس تلك اللذة في الجنة
إذ لا تناسل هناك ولا احتباس، ولما هو أعظم وأتم
وأبقى وهو اللذة بالنظر إلى وجهه الكريم - (١) -

هذا؛ ومما تجدر الإشارة إليه:

أن النكاح من باب تمليك الانتفاع لا من باب تمليك المنفعة؛ من
حيث إن مقتضى عقده أن يباشر الزوج منفعة بنفسه خاصة، وليس له
أن يُمَكِّن غيره من تلك المنفعة؛ لكونه ليس مالكا للمنفعة، ولا لبضع
الزوجة (٢).

والفرق بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين قاعدة
تمليك المنفعة:

أن تمليك الانتفاع عبارة عن: الإذن للشخص في أن
يباشر هو بنفسه فقط، كالإذن في سكنى المدارس والربط والمجالس في
الجوامع والمساجد والأسواق ومواضع النسك كالمطاف والمسعى ونحو
ذلك .

فلمن أذن له في ذلك أن ينتفع بنفسه فقط، ويمتنع في حقه أن
يؤاجر، أو يعاوض بطريق من طرق المعاوضات، أو يسكن غيره لبيت
المدرسة أو غيره من بقية النظائر المذكورة معه .

(١) شرح مختصر خليل للخرشي ١٦٤/٣، أسنى المطالب لأبي زكريا الأنصاري

٩٨/٣

(٢) حاشيتنا قليوبي وعميرة ٢٠٧/٣، أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي المالكي

١٩٣/١



وتمليك المنفعة عبارة عن: الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه أو يُمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة، وبغير عوض كالعارية .

فمن استأجر داراً أو استعارها فله أن يؤجرها من غيره، أو يسكنه بغير عوض، وأن يتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم على جُزئي العادة على الوجه الذي ملكه، فهو تمليك مطلق في زمن خاص حسبما تناوله عقد الإجارة أو شهدت به العادة في العارية، فمن شهدت له العادة في العارية بمدة كانت له تلك المدة ملكاً على الإطلاق يتصرف كما يشاء بجميع الأنواع المائغة في التصرف في المنفعة في تلك المدة ويكون تمليك هذه المنفعة كتمليك الرقاب (١).

(١) أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي المالكي ١٩٣/١ .



المطلب الرابع

الحكم التكليفي للزواج

اختلف الفقهاء في حكم الزواج في حال الاعتدال على قولين:
القول الأول : أنه مندوب إليه، وهو سنة مؤكدة - وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء -.

وقالوا: إن الأوامر الواردة في قوله - ﷺ -: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣]، وقوله - ﷺ -: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: ٣٢]، وقوله - ﷺ -: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: ٢٥]؛ للإباحة مثل الأمر في قوله - ﷺ -: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} [الأعراف: ٣١].

معطين ذلك: بأن الذي صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب هو قول الحق - ﷻ -: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [النساء: ٢٥].

القول الثاني: أن الزواج حال الاعتدال واجب - وهذا القول للظاهرية - .

وقد أخذ الظاهرية وجوب النكاح بناء على ظاهر الأمر الذي يفيد الوجوب في قوله - ﷺ -: {فَانكِحُوا} [النساء: ٣].

وسبب اختلافهم: هل تحمل صيغة الأمر به في قوله - ﷺ -: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣]، وفي قوله - ﷺ -:

(تأكدوا فإنني مكاثر بكم الأمم) وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة في ذلك على الوجوب أم على النذب أم على الإباحة.

فأما من قال إنه في حق بعض الناس واجب، وفي حق بعضهم مندوب إليه ، وفي حق بعضهم مباح: فهو التفات إلى المصلحة . وهذا النوع من القياس هو الذي يسمى المرسل ، وهو الذي ليس له أصل معين يستند إليه وقد أنكره كثير من العلماء والظاهر من مذهب مالك القول به (١).

أما في غير حال الاعتدال:

فالزواج قد ترد عليه الأحكام التكليفية الخمسة وهي: الوجوب، والحرمة، والكراهة، والنذب، والإباحة.

فيختلف الحكم التكلفي للزواج من شخص لآخر باعتبار حال الشخص، وقدرته الصحية ، والمالية والقيام بالأعباء الزوجية على النحو الآتي:

فبكون واجباً: إذا كان الشخص يتيقن الوقوع في الزنى؛ وكان قادراً على تكاليف الزواج ونفقاته؛ لأن الزواج طريق إعفافه، وصونه عن الوقوع في الحرام، فإن لم يستطع فعله بالصوم، وليستعفف حتى يغنيه الله من فضله.

وبكون مندوباً: في حالة الاعتدال ، وهي أن يكون الشخص معتدل الطبيعة ، بحيث لا يخشى الوقوع في الزنى إن لم يتزوج ، ولا

(١) بداية المجتهد ٣/٢.

يخشى أن يظلم زوجته إن تزوج ، وهذا عند جمهور الفقهاء . وقال الشافعية : إن الزواج في هذه الحالة مباح ، يجوز فعله وتركه .
ويكون مباحاً: وذلك للشخص الذي لا شهوة له كالمريض والكبير الذي لا يشتهي النساء لكبر سنه .

ويكون مكروهاً: إذا خاف الشخص الوقوع في الجور والضرر إن تزوج ؛ لعجزه عن الإنفاق أو عدم القيام بالواجبات الزوجية .
ويكون محرماً: إذا كان المرء في حالة يتيقن فيها عدم القيام بأمور الزوجية والإضرار بالمرأة إذا هو تزوج ^(١) .

(١) بداية المجتهد ٣/٢ ، المغني ٦ / ٤٤٦ ، حاشية ابن عابدين ٢ / ٢٦٠ ،
٢٦١ ، مغني المحتاج ٣ / ١٢٤ ، الشرح الصغير ٢ / ٣٣٠ ، حاشية
الدسوقي ٢ / ٢١٤ ، ٢١٥ .

المبحث الثاني

أركان عقد النكاح، وشروط كل ركن

الركن لغة: جانب الشيء الأقوى. وفي الاصطلاح: جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه، كالصيغة في عقد النكاح باتفاق الفقهاء. وقد تباينت آراء الفقهاء في تحديد أركان النكاح؛ فذهب فقهاء الحنفية إلى أن أركان النكاح ركنان: هما الإيجاب والقبول، وهما جزأه اللذان لا يتم بدونهما. فعقد النكاح هو عبارة عن: الإيجاب والقبول. ويقصد بالإيجاب: اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول: اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه (١). وذهب فقهاء المالكية إلى أن أركان النكاح: أربعة: الصيغة، والمحل. الزوج والزوجة، والصداق، والعقد. وذهب فقهاء الشافعية إلى أن أركان النكاح خمسة: الزوج، والزوجة، والولي، والمُشاهدان، والصيغة (٢). وقد عد فقهاء الشافعية الشاهدين من الشروط لا الأركان، وقد غلوا ذلك بأنهما خارجان عن ماهية العقد. والحكمة في عد الشاهدين ركناً واحداً بخلاف الزوج والزوجة: أن شروط الشاهدين واحدة أما شروط الزوج والزوجة فهما مختلفان.

(١) بدائع الصنائع للكاساني ٢ / ٢٢٩ ، العناية شرح الهداية ٢ / ٤٣٤ ، الفقه

على المذاهب الأربعة ، تأليف: عبد الرحمن الجزيري ٤ / ١١.

(٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢ / ٤٢٨ ، حاشية الصوقي ٢ / ٢٩٤.

وذهب فقهاء الحنابلة إلى أن أركانه ثلاثة: زوجان، والإيجاب، والقبول^(١).

وفيما يلي بيان لأركان عقد النكاح والشروط الواجب توافرها فيها، وذلك من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول

الصيغة: حقيقتها، وشروطها

الصيغة ركن في عقد النكاح باتفاق الفقهاء . كما سبق .
وهي عبارة عن: اللفظ الدال على الرضا من الجانبين .
أو بعبارة أخرى: هي ما يظهر الإرادة من لفظ ، أو ما يقوم مقامه من كتابة أو إشارة ، وإظهار الإرادة لا بد منه ، فلا عبرة بالإرادة الباطنة^(٢).

وللصيغة ركنان هما: الإيجاب والقبول .
أما الإيجاب : فذهب جمهور الفقهاء من المالكية ، والشافعية، والحنابلة إلى أنه ما يصدر من ولي الزوجة . والقبول : هو ما يصدر من الزوج أو وكيله .

والمالكية والشافعية يستوي عندهم أن يتقدم القبول على الإيجاب أو يتأخر عنه ما دام قد تحدد الموجب والقابل ، فلو قال الزوج للولي : زوجني أو تزوجت بنتك كان قبولا ، ولو قال الولي بعد ذلك : زوجتك أو

(١) مغني المحتاج ٣ / ٢٢٠ ، روضة الطالبين ٧ / ٢٨٠ ، مطالب أولي النهى

٥ / ١٧٤ ، المغني ٦ / ٧١٢ .

(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية ٦ / ٦٣ .



أنكحتك كان إيجاباً، وانعقد النكاح بذلك . إلا أن المالكية قالوا : يندب تقدم الإيجاب^(١).

أما عند فقهاء الحنابلة فلا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول ولا يجوز أن يتقدم القبول عليه ، قالوا : لأن القبول إنما يكون للإيجاب ، فمضى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه فلم يصح ، فلو قال الزوج : تزوجت ابنتك، وقال الولي : زوجتكها، لم يصح رواية واحدة^(٢) .
وذهب فقهاء الحنفية إلى أن الإيجاب : هو ما يصدر أولاً ، سواء أكان المتقدم هو كلام الزوج أم كان كلام الزوجة أو وليها ، والقبول هو ما يصدر مؤخراً ، سواء أكان صدوره من الزوج أم كان من الزوجة أو وليها^(٣).

شروط الصيغة في عقد النكاح:

يشترط لصيغة عقد النكاح عدة شروط؛ هي:

الشرط الأول: أن تكون بألفاظ النكاح أو التزويج أو ما اشتق

منهما:

وهي: إما صريحة، وإما كناية.

(١) بدائع الصنائع ٧ / ٢٠٧ ، التاج والإكليل ٥ / ٢٢٤ ، نهاية المحتاج ٥ /

٧٦ ، كشف القناع ٦ / ٤٥٦

(٢) المغني ٦ / ٥٣٤ ، كشف القناع ٥ / ٣٧ .

(٣) بدائع الصنائع ٧ / ٢٠٧ ، فتح القدير ٣ / ١٠٥ ، الفتاوى الهندية ١ /

فالشريعة: هي ما كانت بلفظ التزويج والإنكاح وما اشتق منهما، سواء بلفظ الماضي، أم بلفظ المضارع بقرينة تدل على الحال، لا طلب الوعد، أم بلفظ الأمر: زوجني.

والكنائية: هي التي تحتاج إلى نية وأن تقوم قرينة على هذه النية، وهي ألفاظ الهبة أو الصدقة أو التملك أو الجعل، والبيع والشراء، مع نية معنى الزواج. ولا ينعقد بلفظ الإجارة والوصية، ولا بلفظ الإباحة والإحلال والإعارة والرهن والتمتع والإقالة والخلع^(١).

الشرط الثاني: أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد:

وللفقهاء في ارتباط الإيجاب بالقبول في عقد النكاح مع اتحاد

المجلس ثلاثة أقوال:

القول الأول: اشتراط اتحاد المجلس، فلو اختلف المجلس لم ينعقد النكاح كما لو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر، ولا يشترط فيه الفور. وهو مذهب الحنفية، وهو الصحيح عند الحنابلة، وهو ما في المعيار عن الباقي من المالكية.

(١) بدائع الصنائع ٢ / ٢٧٢، حاشية ابن عابدين ٢ / ٢٦٦ فتح القدير ٣ / ٢٤٦، مواهب الجليل ٣ / ٤٤٦،، جواهر الإكليل ١ / ٢٨٤ حاشية الدسوقي ٢ / ٢٢١، نهاية المحتاج ٦ / ٢٠٢، روضة الطالبين ٧ / ٣٦، الفروع ٢ / ٤٢٤ مطالب أولي النهى ٥ / ٥٠، الإنصاف ٣ / ٥٢٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ١ / ٢٣٤، الفقه الإسلامي وأدلته ٩ / ٢٢، الفقه على المذاهب الأربعة ٤ / ١٤.

القول الثاني: اشتراط الفورية بين الإيجاب والقبول في المجلس

الواحد ، وهو قول المالكية ، وهو قول الشافعية ، غير أنهم اختلفوا فيه التفاصيل السير . وضبط القفال الفاصل الكثير بأن يكون زمانا لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا . والأولى ضبطه بالعرف (١) .

القول الثالث: صحة العقد مع اختلاف المجلس ، وهو رواية للحنابلة. وعليها لا يبطل النكاح مع التفرق . وهذا كله عند اتحاد المجلس الحقيقي ، أما مع اتحاد المجلس الحكمي فلا يختلف الأمر عند الحنفية. في اشتراط القبول في مجلس العلم ، وهو الصحيح عند الحنابلة.

واشترط المالكية الفورية في الإيجاب حين العلم . والصحيح عند الشافعية أنه لا ينعقد النكاح بالكتابة . وكذلك إن كان الزوج غائبا وبلغه الإيجاب من ولي الزوجة . وإذا صححنا في المسألتين فيشترط القبول في مجلس بلوغ الخبر وعلى الفور (٢) .

(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٢٦٦ ، حاشية الدسوقي ٢ / ٢٢١ ، نهاية المحتاج ٦ / ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٧ / ٣٦ ، الفروع ٢ / ٤٢٤ مطالب أولي النهى ٥ / ٥٠ ، الإنصاف ٣ / ٥٢٦ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤١ / ٢٣٤ ، الفقه الإسلامي وأدلته ٩ / ٢٢ ، الفقه على المذاهب الأربعة ٤ / ١٤ .

(٢) حاشية الدسوقي ٢ / ٢٢١ ، الإنصاف ٣ / ٥٢٦ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤١ / ٢٣٤ .

الشرط الثالث: ألا يخالف القبول الإيجاب:

فإذا قال شخص لآخر: زوجتك ابنتي على ألف درهم فقال الزوج: قبلت النكاح ولا أقبل المهر لا ينقد النكاح ولو قبل ومكنت عن المهر ينقد أما إذا قالت له: زوجتك نفسي بألف قبلها بألفين فإنه يصح وإن كان القبول يخالف الإيجاب لأن غرضها قد تحقق مع زيادة ، ولكن لا تلزمه الزيادة إلا إذا قبلت في المجلس .
وإذا قال لها زوجيني نفسك بألف فقالت بخمسائة ، فإنه يصح ، ولا يحتاج إلى قبول منه ؛ لأن هذا إبراء ، وإسقاط بخلاف الزيادة ، فإنها لا تلزم إلا القبول^(١).

الشرط الرابع: أن تكون الصيغة مسموعة للعاقدين:

فلا بد أن يسمع كل من العاقدين لفظ الآخر إما حقيقة كما إذا كانا حاضرين أو حكما كالكتاب من الغائب ؛ لأن قراءته قامت مقام الخطاب هنا ، ولا يشترط في الصيغة أن تكون بالفاظ صحيحة بل تصح بالآلفاظ المحرفة على التحقيق ، فإذا كانت المرأة أو وكيلها من العامة الذين لا يحسنون النطق بقول : زوجت : وقالت : زوجتك نفسي أو قال : زوجتك ببنتي فإنه يصح^(٢).

(١) روضة الطالبين ٧ / ٣٦ ، الفروع ٢ / ٤٢٤ مطالب أولي النهى ٥ / ٥٠ ،
الموسوعة الفقهية الكويتية ٤١ / ٢٣٤ ، الفقه الإسلامي وأدلته ٩ / ٢٢ ، الفقه على
المذاهب الأربعة ٤ / ١٤ .

(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية ٤١ / ٢٣٤ ، الفقه الإسلامي وأدلته ٩ / ٢٢ .

الشرط الخامس: ألا يكون اللفظ مؤقتاً بوقت :

فإذا قال لها زوجيني نفسك شهراً بصداق كذا فقالت : زوجت فإنه يقع باطلاً وهذا هو النكاح المؤقت^(١) .

الفرق بين النكاح المؤقت ونكاح المتعة:

والفرق بين النكاح المؤقت ، ونكاح المتعة يظهر في أن نكاح المتعة: أن يقول الرجل لامرأة: متعيني نفسك بهذه العشرة من الدراهم مدة كذا، فتقول له: متعتك نفسي فالحاصل لا بد من لفظ التمتع فيه .
وصورة النكاح المؤقت: أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام أو أكثر أو أقل . والفرق بينهما أن يذكر لفظ التزويج ، والنكاح في المؤقت، ولفظ التمتع في نكاح المتعة^(٢) .

وأدلة تحريم نكاح المتعة كثيرة منها:

ما روي عن علي - عليه السلام -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)^(٣) .
وقال مسلمة بن الأكوع : (رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء عام أوطاس^(٤) ثلاثة أيام، ثم نهى عنها)^(٥) .

(١) فتح القدير ٣ / ١٤٩ ، التمرقني ٢ / ٢١٢ ، مغني المحتاج ٢ / ١٤٢ ، الروض المربع ٣ / ١٤١ ، ٢٧٦ .

(٢) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للقرنوي الحنفى ١ / ٥١ .

(٣) صحيح البخاري : كتاب المغازي، باب غزوة خيبر ، ٧ / ٤٨١ ، حديث ٤٢١٦ .

(٤) يوم فتح مكة ويزوم أوطاس شيء واحد، وأوطاس ولد بالطائف . شرح النووي ٩ / ١٨٤ .

(٥) لمصحيح مسلم ٢ / ١٠٢٢ ، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث ١٨ / ١٤٠٥ .

قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، أي في المتعة، ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها، إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله، وسنة رسوله، وقال القاضي عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها، إلا الروافض (١).

الشرط السادس: عدم التعليق:

فلا يصح مثل: زوجتك ابنتي إن بعثتي الأرض الفلانية، أو يقول: زوجتك ابنتي إن أعطيتني دار كذا، أو إن رضيت بك زوجاً؛ فإنه لا يصح (٢).

(١) فتح القدير ٣ / ١٤٩ ، نيل الأوطار ٦ / ١٣٧ ، السوقي ٢ / ٢١٢ ، مغني المحتاج ٣ / ١٤٢ ، الروض المربع ٣ / ١٤١ ، ٢٧٦ الموسوعة الفقهية الكويتية ٢ / ٣١ ، الفقه الإسلامي وأدلته ٩ / ٢٢ ، الفقه على المذاهب الأربعة ٤ / ١٤ ، تحريم المتعة في الكتاب والسنة، تأليف: يوسف جابر المحمدي ٤ / ١.

(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية ٤١ / ٢٣٤ ، الفقه الإسلامي وأدلته ٩ / ٢٢.

المطلب الثاني

الزواج، وشروطه

يشترط في جانب الزوج في عقد النكاح عدة شروط تلخص

فيما يلي:

الشرط الأول: أن يكون الزوج مسلماً - بالنسبة إلى المسلمة -:

فلا ينعقد زواج المسلمة بغير المسلم، بل هو عقد باطل، ولا

يترتب عليه أي أثر.

وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من كافر،

يهودي أو نصراني أو غيره ^(١)؛ لقوله - ﷺ - : {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ

حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: ٢٢١]، ولقوله - ﷺ - : {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠].

ولأن ﴿الإسلام يعلو ولا يعلى عليه﴾ كما قال النبي - ﷺ - ^(٢).

ولأن في نكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر، لأن

الزواج يدعوها إلى دينه، والنساء في العادات يتبعن الرجال فيما يؤثرون

من الأفعال ويقلدوهم في الدين، وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في آخر

(١) فتح القدير: ٣/٢١، بداية المجتهد: ٢/٧٠، تحفة الطلاب للأنصاري: ص

٣٢٦، المغني: ٧/٥٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٣٤/٤١، الفقه الإسلامي

وأبنته ٢٢/٩.

(٢) أخرجه الدارقطني عن عائذ عن عمرو بن المزني، وفيه مجهولان، ورواه

الطبراني والبيهقي عن عمر، ورواه نهشل عن معاذ، وروي موقوفاً على ابن

عباس (راجع نصب الراية: ٣/٢١٣، سبل السلام: ٤/٦٧).

الآية بقوله -^(١) : {أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} [البقرة: ٢٢١]؛ لأنهم يدعون المؤمنات إلى الكفر، والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار، لأن الكفر يوجب النار، فكان نكاح الكافر المسلمة سبباً داعياً إلى الحرام فكان حراماً، والنص وإن ورد في المشركين لكن العلة وهي الدعاء إلى النار تعم الكفرة أجمع، فيعم الحكم بعموم العلة ^(١).

ويفسخ الزواج باتفاق المذاهب بسبب ردة أحد الزوجين؛ لأن الردة تتضمن تبنيت الغدر والحق والعداوة للمسلمين، فلا يناسبها بقاء الحياة الزوجية التي ينبغي أن تقوم على الوفاء والصفاء والحب والوئام والسلام، ^(٢) وقد قال الله -^(٣) في كتابه العزيز: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: ٢٢١].

الشرط الثاني: أن يكون غير مُحَرَّم على المرأة :

سواء كان هذا التحريم مؤبداً كالتحريم بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة، أو كان تحريماً مؤقتاً كالتحريم بسبب الجمع بين المرأة ومحارمها .

الشرط الثالث: أن الزوج يكون معيناً: فلا يصح نكاح المجهول.

^(١) الهدائع الصنائع ٢ / ٢٧١، المبسوط للمرخصي ٤ / ٢١١، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ٣ / ١٠٢، وتفسير القرطبي ٣ / ٧٠، والشرح الكبير ٢ / ٢٦٧، والخطاب ٣ / ٤٧٧، والمجموع ١٦ / ١٣٦، وروضة الطالبين ٧ / ١٣٦، والمغني لابن قدامة ٧ / ١٣١.

^(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية ٤١ / ٢٣٤، الفقه الإسلامي وأدلته ٩ / ٢٢.

الشرط الرابع: أن يكون الزوج مختاراً غير مكروه:

فلا يصح نكاح المكروه ، ويقع نكاحه باطلاً عند جمهور الفقهاء ؛
لقول النبي - ﷺ -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأَ ، وَالْبَشْيَانِ وَمَا
اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ ﴾ (١).

الشرط الخامس: ألا يكون الزوج جاهلاً جل المرأة له: فلا يجوز

أن يتقدم لنكاح امرأة، وهو جاهل بجلها (٢).

الشرط السادس: أن يكون الزوج كفئاً للزوجة:

فيرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة (٣) تطلب للنساء لا للرجال،
بمعنى أن الكفاءة تعد في جانب الرجال للنساء، فهو حق في صالح
المرأة لا في صالح الرجل، فيشترط أن يكون الرجل مماثلاً أو مقارباً لها
في أمور الكفاءة.

(١) أخرجه ابن ماجه (٦٥٩ / ١) والحاكم (١٩٨ / ٢) من حديث عبد الله بن

عباس - ﷺ - وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي .

(٢) الفقه الإسلامي وأدلته ٨٤/٩، الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ١٤/٤.

(٣) الكفاءة: المماثلة بين الزوجين دفعاً للعار في أمور مخصوصة؛ كالدين،

والنسب، والحرفة، واليسار إلخ. (الدسوقي: ٢/ ٢٤٨، كشف القناع: ٥/

٧٢، مغني المحتاج: ٣/ ١٦٤، الباب: ٣/ ١٢، الفقه الإسلامي وأدلته

٢١٦/٩).

ولا يشترط في المرأة أن تكون مساوية للرجل أو مقاربة له، بل يصح أن تكون أقل منه في أمور الكفاءة؛ لأن الرجل لا يعير بزوجة أدنى حالا منه، أما المرأة وأقاربها فيعبرون بزواج أقل منها منزلة (١).

المطلب الثالث

الزوجة، وشروطها

ليست كل امرأة صالحة للعقد عليها، بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها عدة شروط .

وبيان هذه الشروط فيما يلي:

١. أن تكون معينة:

كأن يسميها باسمها، أو يصفها بوصف لا ينطبق إلا عليها، أو يشير إليها إن كانت حاضرة، فالتعيين يكون بواحد من هذه الأمور الثلاثة:

مثال الأول - أن يسميها باسمها -:

كأن يكون هناك رجل له ابنتان إحداهما زينب، والثانية فاطمة، فيقول: زوجتك ابنتي فاطمة؛ فهذا تعيين، وليس له أن يقول زوجتك إحدى ابنتي، إذ في هذه الحال لم يعين من هي؟ .

مثال الثاني - أن يصفها بوصف لا ينطبق إلا عليها -:

(١) بدائع الصنائع ٢/ ٣٢٠، حاشية الدسوقي: ٢/ ٢٤٩، مغني المحتاج ٣/ ١٦٤،

كشف القناع ٥/ ٧٢.

أن يكون له ابنتان إحداهما طويلة والثانية قصيرة، فيقول: زوجتك ابنتي القصيرة، وهذا الوصف لا يتصف به الأخرى، فهذا تعيين صحيح. مثال الثالث - التعيين بالإشارة -:

أن تكون بناته عنده في المجلس لكنهن متغطيات، فيقول: زوجتك هذه، ويشير إليها، فهذا تعيين صحيح.

اعتراض وجوابه:

اعترض على شرط التعيين هذا بقوله - عنه - حكاية عن شعيب لموسى - عليه السلام -: { قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَاجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ } [القصص: ٢٧]؛ فهذا لم يعينها لموسى - عليه السلام - .

وأجيب: بأن قوله - عنه -: { أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ } إنما هو للتخير، أي: خذ من شئت منهما، وهذا يستلزم من موسى - عليه السلام - أن يعينها، فلما عينها زوجه إياها، فهذا عينها بعد الإبهام وهذا الصحيح.

٢. أن تكون أنثى محقة الأنوثة:

فلا ينعقد الزواج على الرجل أو الخنثى المشكل : وهو الذي لا يستبين أمره ، أهو رجل أم أنثى ، ويكون الزواج على خنثى باطلاً (١) .

(١) الفقه الإسلامي وأدلته ٨٤/٩، الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ١٤/٤.

٣. أن تكون ذات دين سماوي:

والكتابية ذات دين سماوي في الأصل، فهي تشترك مع المسلم في الإيمان وبرمالاته، وبالدار الآخرة وبالقيم الأخلاقية، والمثل الروحية التي توارثتها الإنسانية عن النبوات، وذلك في الجملة لا في التفصيل طبعاً .

وهذا يجعل المسافة بينها وبين الإسلام قريبة، لأنه يعترف بأصل دينه، ويقر بأصوله في الجملة، ويزيد عليها ويتممها بكل نافع وجديد. فيجوز للمسلم أن يتزوج ذمية، إذا كانت كتابية كاليهودية والنصرانية؛ لقوله - ﷺ - : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائدة: ٥] بعد قوله - ﷺ - : {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ} [المائدة: ٥].

٤. أن لا تكون هذه الزوجة محرمة على الرجل تحريمًا قاطعاً لا شبهة فيه:

فلا ينعقد الزواج بالمحارم كالبنات والأخت والعمة والخالة، كما لا ينعقد بمن تعلق بها حق رجل آخر كالمتزوجة بزواج آخر، والمعتدة من وفاة أو طلاق، فإن الزواج في كل هذه الحالات باطل (١).

(١) الفقه الإسلامي وأدلته ٨٤/٩، الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ١٤/٤.

والمحرمات من النساء نوعان:

النوع الأول : محرمات حرمة مؤبدة:

وهن اللاتي تكون حرمة نكاحهن مؤبدة؛ لأن سبب التحريم ثابت لا يزول، كالأمومة، والبنوة، والأخوة .

وأسباب التحريم المؤبد ثلاثة: هي النسب، والمصاهرة، والرضاع^(١)، وبيانها كما يلي:

أولاً: المحرمات بسبب النسب:

والأصل في ذلك قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: ٢٣].

فالمحرمات من النسب سبع : هن الأمهات ، البنات ، الأخوات ، العمات ، الخالات ، بنات الأخ ، بنات الأخت ، وهن محرمات على التأبيد فلا يحل الزواج بهن بحال من الأحوال وبيانها كما يلي :

١ - الأمهات : وهي اسم لكل أنثى لها عليك ولادة . فيدخل في ذلك الأم ، وأمهاتها، وجداتها، وأم الأب، وجداته ، وإن علون.

٢ - البنات : وهي اسم لكل أنثى لك عليها ولادة ، أو كل أنثى يرجع نسبها اليك بالولادة بدرجة أو درجات. فيدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها.

(١) فتح القدير ٣ / ١١٩ ، بدائع الصنائع ٢ / ٢٥٧ ، الفواكه الدواني ٢ / ٣٦ ،

٣٧ ، مغني المحتاج ٣ / ١٧٥ ، حاشية الدسوقي ٢ / ٢٥٠ ، شرح الزرقاني

٣ / ٢٠٤ ، المغني ٦ / ٥٧٨ ، كشف القناع ٥ / ٦٩ .

٣ - الأخوات: وهي اسم لكل أنثى جاورتك في أصلك أو في أحدهما. وبذلك يشمل التحريم الأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، والأخت

لأم^(١).

٤ - العمات : و هي اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصله أو في أحدهما. وقد تكون العمّة من جهة الأم ، وهي أخت أبي أمك. وبذلك يشمل التحريم : العمّة الشقيقة ، والعمّة لأب ، والعمّة لأم^(٢).

٥ - الخالات : و هي اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصلها أو في أحدهما. وقد تكون الخالة من جهة الأب ، وهي أخت أم أبيك. وبذلك يشمل التحريم : الخالة الشقيقة ، والخالة لأم ، والخالة لأب .
٦ - بنات الأخ : وهي اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة. وبذلك يشمل التحريم بنت الأخ الشقيق ، وبنت الأخ لأب ، وبنت الأخ لأم .

(١) بدائع الصنائع ٢ / ٢٥٧ ، بداية المجتهد ٢ / ٣٢ ، مغني المحتاج ٣ / ١٧٥ ، حاشية السوقي ٢ / ٢٥٠ ، شرح الزرقاني ٢ / ٢٠٤ ، المغني ٦ / ٥٧٨ ، كشاف القناع ٥ / ٦٩ .

(٢) المبسوط للرخسي ٤ / ١٩٨ ، بدائع الصنائع ٢ / ٢٥٧ ، مغني المحتاج ٢ / ١٧٥ ، حاشية السوقي ٢ / ٢٥٠ ، شرح الزرقاني ٢ / ٢٠٤ ، المغني ٦ / ٥٧٨ ، كشاف القناع ٥ / ٦٩ ، الأذلة الرضية لمن الدرر البهية في المسائل الفقهية ١ / ١٢١ .

٧ - بنات الأخت: وهي اسم لكل أنثى لاختك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة. وبذلك يشمل التحريم بنت الأخت الشقيقة ، وبنت الأخت لأب، وبنت الأخت لأم^(١).

ثانياً: المحرمات بسبب المصاهرة:

المصاهرة: هي القرابة الناشئة بسبب الزواج .

قال الجوهري : الأصهار أهل بيت المرأة ، وقال : ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعاً ، يقال : صاهرت إليهم : إذا تزوجت فيهم ، وأصهرت بهم : إذا اتصلت بهم وتحرمت بجوار أو نسب أو تزوج^(٢) .

وإصطلاحاً: تطلق على قرابة النكاح^(٣).

ويحرم بسبب المصاهرة أربعة أنواع :

(١) بدائع الصنائع ٢ / ٢٥٧ ، مغني المحتاج ٣ / ١٧٥ ، حاشية السمرقني ٢ / ٢٩٠ ، شرح الزرقاني ٣ / ٢٠٤ ، المغني ٦ / ٥٧٨ ، كشاف القناع ٥ / ٦٩ ، نيل المرام شرح آيات الأحكام ١ / ١٣٥ .

(٢) مختار الصحاح، تأليف : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: مادة (صهر) ١ / ٣٧٥ ط / مكتبة لبنان ناشرون - بيروت . الطبيعة طبيعة جديدة ، ١٤١٥ - ٩٩٥ م ، تحقيق : محمود خاطر ، الصحاح في اللغة ١ / ٣٩٨ .

(٣) المبسوط للرخسي ٤ / ١٩٨ ، بدائع الصنائع ٢ / ٢٥٧ ، مغني المحتاج ٣ / ١٧٥ ، حاشية السمرقني ٢ / ٢٥٠ ، شرح الزرقاني ٣ / ٢٠٤ ، المغني ٦ / ٥٧٨ ، كشاف القناع ٥ / ٦٩ ، الأذلة للرضية لمسن الدرر النبيه في المسائل

١. زوجة الأب: وإن علا سواء أكان من العصبات كإبي الأب

، أم من ذوي الأرحام كإبي الأم ، ويمجّد عقد الأب عليها عقداً صحيحاً تصبح محرمة على فرعه، وإن لم يدخل بها؛ لقوله -^(١) -: لا يكره ما تكح أبناؤكم من النساء إلا ما قد سلفت إنه كان فاحشةً ومنهنا ولداءً تنبأ { النساء: ٢٢}.

ولا يدخل في التحريم أصول هذه المرأة، ولا فروعها ^(١).

وكما تدل الآية على حرمة زوجة الأب، تدل على حرمة زوجة الجد وإن علا؛ لأن لفظ الأب يطلق على الجد وإن علا؛ ولأن زواج من تزوج بهنّ الأباء يتنافى مع المروءة، وترفضه مكارم الأخلاق وثأبها المطابع النيلية ^(٢).

٢. أم الزوجة: وأم أمها، وأم أبيها وإن علت.

وهذه محرمة بالكتاب والسنة:

أولاً: الكتاب: قوله -^(١) -: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣]؛ عطفاً على قوله -^(٢) -: {حُرُمَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّائِكُمْ وَأَخَالَاتُكُمْ...} [النساء: ٢٣].

^(١) لرد المحتار ٢ / ٥٢٧، الحاوي الكبير ١٣ / ٢١٤، ٢١٥، بداية المجتهد ٢ / ٨٧، عقد الجواهر الثمينة ٢ / ٤٨، ٤٩، القوانين الفقهية ص ٢١٥، شرح منتهى الإرادات ٣ / ١٨٧، المغني ١٠ / ٥٤٨، ٥٤٩.

^(٢) بدائع الصنائع ٢ / ٢٥٧، مغني المحتاج ٣ / ١٧٥، حاشية السموقي ٢ / ٢٥٠، شرح الزرقاني ٣ / ٢٠٤، المغني ٦ / ٥٧٨، كشف القناع ٥ / ١٩٠، نيل السمر شرح أبيات الأحكام ١ / ١٣٥.

ضقة الأسرة ضمة الشريعة الاسلاميه

وثبتت حرمة أصول المرأة كاملها ووجدتها بمجرد العقد عليها؛ حيث إن قول الحق -ﷺ-: {وَأَمَهَاتُ نِسَائِكُمْ} مطلق غير مقيد بشرط الدخول لم يرد فيه شرط ولا استثناء ، وإن الدخول في قوله -ﷺ-: {بِمَنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} راجع إلى: {وَأَنزَلْنَاهُنَّ} لا إلى المعطوف عليه، وهو: {وَأَمَهَاتُ نِسَائِكُمْ} فيبقى النص على حرمة أمهات النساء، سواء دخل بها أو لم يدخل .

وما دام النص جاء مطلقاً فيجب بقاؤه على إطلاقه ما لم يرد دليل يقينه ، وروي عن عبد الله بن عباس -ﷺ- أنه قال في قوله -ﷺ-: {وَأَمَهَاتُ نِسَائِكُمْ}: أبهما ما أبهما الله ، أي أطلقوا ما أطلق الله ، كما روي عن عمران بن حصين -ﷺ- أنه قال : الآية مبهمه ، لا تفرق بين الدخول وعلمه ^(١).

ثانيا : من السنة:

ما روي أن النبي -ﷺ- قال : {أيما رجل تزوج امرأة فطلقها قيل أن يدخل بها ، أو ماتت عنده ، فلا يحل له أن يتزوج بأمها} ^(٢). وهذا معنى قول الفقهاء : العقد على البنات يحرم الأمهات ^(٣).

(١) بدائع الصنائع ٢ / ٢٥٧ ، مفتي المحتاج ٢ / ١٧٥ ، حاشية السوفاي ٢ / ٢٥٠ ، لمضي ٦ / ٥٧٨ ، كشف القناع ٥ / ٦٩ .

(٢) حديث : "أيما رجل تزوج امرأة أخرجه البيهقي (السنن الكبرى ٧ / ١٠) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهذا المعنى ، وفي إسناده ابن أبي عمير وهو ضعيف (التلخيص الحبير ٣ / ١٦٦) .

(٣) بدائع الصنائع ٢ / ٢٥٧ ، مفتي المحتاج ٢ / ١٧٥ ، حاشية السوفاي ٢ / ٢٥٠ ، شرح ثرغوثي ٢ / ٢٠١ ، لمضي ٦ / ٥٧٨ ، كشف القناع ٥ / ٦٩ .

٣. فروع الزوجة:

وهن بناتها ، وبنات بناتها ، وبنات أبنائها وإن نزلن ؛ لأنهن من بناتها بشرط الدخول بالزوجة ، وإذا لم يدخل فلا تحرم عليه فروعهما بمجرد العقد ، فلو طلقها أو ماتت عنه قبل الدخول بها ، فله أن يتزوج بنتها .

وهذا معنى قول الفقهاء: الدخول بالأمهات يحرم البنات^(١) .

يدل لذلك قول الحق - ﷻ - في آية المحرمات {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: ٢٣] ، عطفاً على قوله - ﷻ - : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ...} [النساء: ٢٣] .

فيكون المعنى تحريم النِّزَاج بالربائب اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن^(٢) .

والربائب: جمع ربيبة ، وربيب الرجل ، ولد امرأته من غيره ، سمي ربيباً له ، لأنه يربه أي يسومه ، والربيبة ابنة الزوجة .

(١) معني المحتاج ٢ / ١٧٥ ، حاشية المسوقي ٢ / ٢٥٠ ، المعني ٦ / ٥٧٨ ، كشاف القناع ٥ / ٦٩ .

(٢) بدائع الصنائع ٢ / ٢٥٧ ، معني المحتاج ٢ / ١٧٥ ، حاشية المسوقي ٢ / ٢٥٠ ، شرح الرزقاني ٢ / ٢٠٤ ، المعني ٦ / ٥٧٨ ، كشاف القناع ٥ / ١٢٥ ، نيل المرام شرح أبيات الأحكام ١ / ١٣٥ .

فتحة الأسرة ضحي الشريعة الإسلامية

وهي حرام على زوج أمها بنص الآية ، سواء أكانت في الحجر أم لم تكن، وهي تحظى بما تحظى به البنت الصليبة من عطف ورعاية، وأما تحريم بنات الرزية وبنات الرتيب فثبت بالإجماع^(١).
ووصف الرزية بأنها في الحجر ليس للتقيد ، بل خرج مخرج الغالب لبيان قبح التزوج بها، لأنها غالباً تتربى في حجره كابنه وابنته، فلها ما لبنته من تحريم .

٤. زوجة الفرع:

أي زوجة ابنه ، أو ابن ابنه ، أو ابن بنته ، مهما بعدت الدرجة ، سواء دخل الفرع بزوجه أو لم يدخل بها .

يدل لذلك قول الحق -ﷺ- في آية المحرمات : {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: ٢٣].

والحلائل: جمع حليلة وهي الزوجة ، سميت حليلة ، لأنها تحل مع الزوج حيث حل ، وقيل: حليلة بمعنى محلة، ولأنها تحل للابن. وقيدت الآية أن يكون الأبناء من الأصلاب ، لإخراج الأبناء بالبنّي، فلا تحرم زوجاتهم لأنهم ليسوا أبناءه من الصلب .
وعلى هذا قصر الأئمة الأربعة فهمهم للآية ، ولم يخرجوا بها زوجة الابن الرضاعي ، بل هي محرمة كزوجة الابن الصليبي ،

^(١) فتح لقير ٣ / ١١٩ ، مغني المحتاج ٢ / ١٧٥ ، كشف القناع ٥ / ٦٩ .

مستثنين إلى قول النبي - ﷺ -: ﴿يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ
الْوِلَادَةِ﴾ وَيُرْوَى: ﴿مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ﴾^(١).

أما أصول زوجة الفرع ، وفروعها ، فغير محرمات على الأصل ،
فله أن يتزوج بأم زوجة فرعه أو بابنتها .

وقد اتفق الفقهاء على أن حرمة المصاهرة كما تثبت بالعقد
الصحيح في زوجة الأصل ، وأصل الزوجة ، وزوجة الفرع ، وفرع
الزوجة بشرط الدخول بأنها تثبت كذلك بالدخول في عقد الزواج الفاسد
، وبالدخول بشبهة ، كما إذا عقد رجل زواجه بامرأة ، ثم زفت إليه غيرها
فدخل بها ، كان هذا الدخول بشبهة ، وبالدخول بملك اليمين ، كما إذا
واقع السيد جاريته المملوكة فيحرم عليه أصولها وفروعها ، وتحرم هي
على أصوله وفروعه^(٢) .

(١) صحيح البخاري : كتاب الشهادات ، باب الشهادة على الأنساب والرضاع
المستفيض ، ٢٠٠/٥ ، حديث ٢٦٤٤ ، ومسلم ١٠٦٨/٢ ، كتاب الرضاع : باب
يحرم من الرضاة ما يحرم من الولادة ، حديث ١٤٤٤/٢ .

(٢) حاشية السوقي ٢ / ٢٥٠ ، شرح الزرقاني ٣ / ٢٠٤ ، المغني ٦ / ٥٧٨ ،

ثالثاً: المحرمات بسبب الرضاع:

الأصل في التحريم بسبب الرضاع:

قوله - رحمه الله -: (وأُمَّهُنَّ لَكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ)

[النساء: ٢٣].

وقوله - رحمه الله -: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ) (١).

أي النسب .

ويحرم من النساء بسبب الرضاع ما يلي:

١ - أصول الشخص من الرضاع: أي أمه التي أرضعته وأُمها ، وإن علت ، ولم أبيه رضاعاً وأُمها وإن علت ، فإذا رضع طفل من امرأة صارت أُمّه من الرضاع ، وصار زوجها الذي كان السبب في ذرّ لبنها أباً من الرضاع .

٢ - فروعهُ من الرضاع: أي بنته رضاعاً ، وبنتها وإن نزلت ، وبنت ابنها رضاعاً وبنتها ، وإن نزلت ، فإذا رضعت بنت من امرأة صارت ابنةً رضاعاً من هذه المرأة ، ولزوجها الذي كان السبب في ذرّ لبنها .

٣ - فروع أبويه من الرضاع: أي أخوانه رضاعاً ، وبنتين ، وبنت وإخوته رضاعاً ، وبنتين ، وإن نزلن ، فإذا رضع طفل من امرأة صارت بنتها أخواتٍ له ، وحرمن عليه ، سواء البنت التي رضعت معه ، أو البنت التي رضعت قبله أو بعده .

(١) صحيح مسلم: كتاب الرضاع، باب ما يحرم من الرضاعة وما يحرم من الولادة ٢/ ١٠٧١، حديث ١٤٤٥، سنن النسائي ٦/ ١٠٤، كتاب النكاح .

٤ - - فروع جنيته إذا انفصلن بدرجة واحدة: أي عماتهن ، وحالات

رضاعاً ، وهؤلاء يحرمين نسباً ، فكذلك يحرمين رضاعاً .

وأما بنات عماتهن وأعمامهن رضاعاً ، وبنات خالاتهن وأخواتهن رضاعاً ، فلا يحرمين عليه ^(١).

كيفية معرفة قرابة الرضاع المحرمة

تعرف قرابات الرضاع المحرمة كلها ، بأن يفرض انتراع الرضيع من أمهته النسبية ، ووضعته ، وفروعه فقط في أسرته الرضاعية ، بوصفه ابناً رضاعياً لمن أرضعته ، ولزوجها الذي در لبنها بسببه ، فكل صلة تقتدر له أو لفروعه بهذا الوضع الجديد فهي التي تجعل أساساً للتحريم أو التحليل بالرضاع .

أما صلة الأسرة الرضاعية بأمة الرضيع النسبية بسبب رضاعه فلا أثر لها في تحريم أو تحليل ، ولهذا لا يثبت لأقاربه النسبيين غير فروعه مثل ما يثبت له هو بهذا الرضاع ^(٢) .

المصور المستثناة من التحريم بالرضاع

خرج القاعدة التفهيمية المستمدة من قول النبي - ﷺ -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) عدة صور مستثناة من التحريم بالرضاع ، وإن كانت محرمة من النسب منها :

(١) فتح القير ٢ / ١١٩ ، مغني المحتاج ٢ / ١٧٥ ، كشف القناع ٥ / ١٩٠ .
(٢) بدائع الصنائع ٤ / ٤ ، فتح القير ٢ / ١٢١ ، حاشية السوقي ٢ / ٥٠٣ ،
٥٠٤ ، التواكه الدراني ٢ / ٢٨ ، ٨٩ ، مغني المحتاج ٢ / ١٧٦ ، ١٧٧ ،
٤١٨ ، كشف القناع ٥ / ٧٠ ، ٧١ ، المغني ٦ / ٥٧١ .

الصورة الأولى: أم الأخ أو الأخت من الرضاع ، فإنه يجوز

الزواج بها ؛ لأنها أجنبية عنه ، ولا يجوز الزواج بأُم الأخ أو الأخت من النسب ، لأنها إما أن تكون أمه ، أو تكون زوجة أبيه فتحرم عليه ، وهذه الصلة متقية في صورة أم الأخ أو الأخت رضاعاً ^(١) .

الصورة الثانية: أخت الابن من الرضاع : فإنها لا تحرم على الأب من الرضاعة، سواء أكانت أخت هذا الابن أو البنت من الرضاعة اختاً له من النسب أم اختاً له من الرضاعة من امرأة أخرى ، لأنها ستكون أجنبية عنه .

فإذا رضع طفل من امرأة فلا يبي هذا الطفل أن يتزوج بنت هذه المرضعة، وهي أخت ابنه من الرضاع ، أما أخت الابن أو البنت نسباً، فلا يجوز لأنها ستكون بنته أو بنت زوجته المدخول بها .

الصورة الثالثة: جدة ابنه أو بنته من الرضاع : فيجوز للأب من الرضاعة أن يتزوجها لعدم وجود علاقة تربطها به في حين أن جدة الابن أو البنت نسباً ، إما أن تكون أمه هو فتحرم عليه ، وإما أن تكون أم زوجته فتحرم عليه أيضاً ^(٢) .

(١) البائع المصانع ٤ / ٤ ، فتح القدير ٣ / ١٢١ ، حاشية السموقي ٢ / ٥٠٣ ،

٥٠٤ ، الفواكه الدواني ٢ / ٣٨ ، ٨٩ ، مفتي المحتاج ٣ / ١٧٦ ، ١٧٧ ،

٤١٨ ، كشاف القناع ٥ / ٧٠ ، ٧١ ، المفتي ٦ / ٥٧١ .

(٢) البائع المصانع ٤ / ٤ ، فتح القدير ٣ / ١٢١ ، حاشية السموقي ٢ / ٥٠٣ ،

٥٠٤ ، الفواكه الدواني ٢ / ٣٨ ، ٨٩ ، مفتي المحتاج ٣ / ١٧٦ ، ١٧٧ ،

٤١٨ ، كشاف القناع ٥ / ٧٠ ، ٧١ ، المفتي ٦ / ٥٧١ .

قال الشَّريبي الخطيب : الحرمة تسري من المرضعة، والفعل إلى أصولهما، وفروعهما، وحواشييهما، ومن الرضيع إلى فروعها فقط^(١). ومتى ثبت الرضاع بين الزوجين وجب عليهما أن يفترا من تنقاه، نفسيهما، وإلا فزق القاضي بينهما، حيث تبين أن عقد الزواج فاسد^(٢). والمراد بالتحريم المؤقت: هو ما كان سبب التحريم فيه وصفاً يمكن أن يزول كالجمع بين الأختين، أو المتروجة من الغير، أو المعتدة من الغير، أو من لا تدين بدين سماوى .

ويحرم من النساء تحريماً مؤقتاً أربعة أصناف:

١. ما تعلق بها حق الغير:

وهي زوجة الغير ومعتدته؛ فيحرم على المسلم أن يتزوج من تعلق حق غيره بها بزواج أو عدة من طلاق أو وفاة، أو دخول في زواج فاسد، أو دخول بشبهة .

يدل لذلك قول الحق - ﷺ -: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٤] عطفاً على المحرمات المذكورات في قوله - ﷺ -: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣].

(١) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٤٧٩/٢ ، مغني المحتاج ٤١٨/٣ ، نهاية المحتاج ١٧٧/٧ ، حاشية الجمل ٣٢١/٩ ، حاشية البجيرمي على الخطيب ٣١١/١ .

(٢) مغني المحتاج ١٧٥/٣ ، حاشية النسوي ٢٥٠/٢ ، شرح الزرقاني ٢/ ٢٠٤ ، المغني ٥٧٨/٦ ، كشف القناع ٦٩/٥ .

والمراد بالمحصنات من النساء: المتزوجات منهن ، سواء أكن زوجها مسلماً أم غير مسلم ، كما يحرم على المسلم أن يتزوج معتدة غيره من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة .

والحكمة في هذا: منع الإنسان من الاعتداء على غيره بالتزوج من زوجته أو معتدته ، وحفظ الأنساب من الاختلاط والضياح . وقد ألحق الفقهاء بعدة الطلاق عدة الدخول في زواج فاسد ، وعدة الدخول بشبهة ، لأن النسل من كلٍ منهما ثابت النسب .

الآثار المترتبة على نكاح المعتدة من الغير:

يترتب على نكاح المعتدة من الغير آثار منها:

أ - وجوب التفريق بينهما:

إن نكاح المعتدة من الغير يعتبر من الأنكحة الفاسدة المتفق على فسادها ويجب التفريق بينهما ، وهذا باتفاق الفقهاء .

رَوَى مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَمُسْلِمَانَ بْنِ يَسَارٍ: " أَنَّ طَلِيحَةَ كَانَتْ تَحْتَ زَيْدِ النَّفْثِيِّ فَطَلَّقَهَا أَلْبَنَّةُ فَتَكَحَّتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ وَضَرَبَ رُوجَهَا بِالذِّرَةِ ضَرْبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ رُوجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدْتُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ رُوجِهَا الْأَوَّلِ ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدْتُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ رُوجِهَا الْأَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدْتُ مِنَ الْآخِرِ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا " .



قَالَ النَّبِيُّ: وَرَأَى النَّبِيُّ عَنْ أُمِّتٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَنْزِلٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَجَعَ فَقَالَ: ﴿لَهَا مَهْرُهَا وَنَجْمَعَانِ إِنْ شَاءَ﴾ (١).

ب - وجوب المهر والمدة :

اتفق الفقهاء على عدم وجوب المهر في نكاح المعتدة في عتبتها إذا فرق بينهما قبل الدخول ، ويتفق الفقهاء على وجوب المهر في هذا النكاح بالدخول - أي بالوطء - وعلى وجوب المدة كذلك .
وذلك لما روى عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ رِزَّانٍ أَبِي صُرَّ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ' أَنَّهُ فَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجَ فِي عَدَّتِهَا أَنَّهُ يَفْرُقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَتَكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ ، وَتَعْتَدُ مِنَ الْآخِرِ ' (٢) .

٣. المعلقة ثلاثاً بالنسبة لمن طلقها:

هذا هو الصنف الثاني من المحرمات على سبيل الناقية، وهي التي طلقها زوجها طلاقاً باتاً؛ فلا تحل لمطلقها هذا حتى تنكح زوجاً غيره.

(١) أخرجه مالك في الموطأ ٥٨٩/٢، ٥٩٠، كتاب الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، رقم ٨٤، والشافعي في الأم ٣٢٤/٥، كتاب العدد: باب هذه الحرة، من الشيباني ٤٣٠/٧.

(٢) أخرجه الشافعي في الأم ٣٢٧/٥، كتاب العدد: باب اجتماع العتتين، وفي المسند ٥٧/٢، رقم ١٨٦، وشمس في السنن الكبرى ٤٤١/٧.

يدل لذلك: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن طلقا أن يقيما خدوة الله وشدة خدوة الله بينهما لقوم يعلمون} [البقرة: ٢٢٠].

فيحرم على المسلم أن يتزوج امرأة طلقها ثلاث تطليقات، لأنه استنفد ما يملكه من عدد طلاقاتها، وبانت منه بينونة كبرى، وصارت لا تحل له إلا إذا انقضت عدتها منه، ثم تزوجها زوج آخر زواجا صحيحا، ودخل بها حقيقة، ثم فارقها هذا الآخر، وانقضت عدتها منه؛ لقوله - ﷺ -: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِخْتِسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩] ثم قال - ﷺ -: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّقَا أَنْ يَقيِمَا خُدُورَهُ اللَّهُ وَلِتَلَكْ خُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة: ٢٣٠].

وروى عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني فبنت طلاق، فترجعت بعده عبد الرحمن بن الزبير وأمسأ معه مثل هدبة الثؤيب. فقبس رسول الله - ﷺ - وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تئوقي عسيلة وتذوق عسيلاتك»^(١).

(١) صحيح البخاري ٢/٢٤٩، كتاب الشهادات: باب شهادة المختبي، حديث ٢٦٢٩، ومسلم ٢/١٠٥٥-١٠٥٦، كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حديث ١٤٣٣/١١١، سنن الترمذي ٢/٢٩٣، كتاب النكاح: باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا، حديث ١١١٨، سنن النسائي ١/١٤٨، كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثا.

٣٠ من لا تحدين بدين سماوي:

فلا يحل للمسلم أن يتزوج امرأة لا تحدين بدين سماوي، ولا تؤمن برسول، ولا كتاب إلهي، بأن تكون مشركة تعبد غير الله كالوثنية والمجوسية.

وهذه التحريم ليس على التأييد؛ فإذا دانت بين سماوي حل له أنذاك أن ينكحها .
يل لذلك:

- قوله - ﷺ -: (لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ)
[البقرة: ٢٢١].

والمشركة من لا تؤمن بكتاب من الكتب التي أنزلها الله - ﷻ - ولا برسول من الرسل الذين أرسلهم الله لهداية عباده إلى الصراط المستقيم .

قوله - ﷻ -: (سُئِلُوا بِؤْمُنْ مُنَّةِ أَفْلَ الْكِتَابِ غَيْرَ فَاجِبِي بَسَائِلِهِمْ وَأَكْبَى ذُنَائِبِهِمْ) (١) .

ما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله - ﷺ - إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل،

(١) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٧٨)، والبيهقي في السنن (٩/ ١٩٢).

ومن أصر ضربت عليه الجزية على أن لا توكل لهم
ذبيحة ، ولا تنكح لهم امرأة^(١).

٤. الجمع بين الأختين ومن في حكمهما:

لقوله -ﷺ-: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٣]، وما روى عن أبي هريرة بلفظ: ﴿ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ﴾^(٢).

وقد استنبط الفقهاء من النصين: القرآني والنبوي قاعدة لتحريم
الجمع بين المحارم هي:

« يحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً، لا يجوز له
نكاح الأخرى من الجانبين جميعاً » .
أو بعبارة أخرى « يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما قُبرِت
ذكرًا، حرمت عليه الأخرى »^(٣).

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم ١٠٠٢٨، وابن أبي شيبه ٤٢٩/٦، كتاب
الجهاد: باب ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية، رقم ٣٢٦٤٥.

(٢) صحيح البخاري ١٦٠/٩، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها،
حديث ٥١٠٩، صحيح مسلم ١٠٢٨/٢، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين
المرأة وعمتها أو خالتها، حديث ١٤٠٨/٣٣.

(٣) البدائع للصنائع ٢ / ٢٦٢، الدر المختار ٢ / ٣٩١ مغني المحتاج ٣ / ١٨٠،
اللباب ٦ / ٣، المهذب ٢ / ٤٣، بداية المجتهد ٢ / ٤٢، المغني ٦ / ٥٧٤، كشف
القناع ٥ / ٨٠.



وقد أشار النبي - ﷺ - إلى علة النهي في رواية ابن حبان وغيره:
(إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) ^(١).

٥. الجمع بين أكثر من أربع زوجات:

لقوله - ﷺ -: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣].

وما روى أن ثُوْقَلْ بْنَ مُعَاوِيَةَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ خُمُسُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ
النَّبِيُّ - ﷺ -: {أَمِنِكَ أَرْبَعًا وَفَارِقَ الْأُخْرَى} ^(٢).

فيحرم على المسلم أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، فلا يتزوج بخامسة ما دامت في عصمته أربع سواها، إما حقيقة بأن لم يطلق إحداهن، وإما حكماً، كما إذا طلق إحداهن ولا تزال في عدته، ولو كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى، وهذا عند الحنفية.

وأما فقهاء المالكية والشافعية، فقد أجازوا التزوج بخامسة إذا كانت إحدى الزوجات الأربع في العدة من طلاق بائن؛ لأن الطلاق

^(١) صحيح البخاري ١٦٠/٩، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث ٥١٠٨.

^(٢) أخرجه البيهقي في المنن الكبرى ١٨٤/٧، كتاب النكاح: باب من يسلم وعده أكثر من أربع نسوة.



البائن يقطع الزوجية بين الزوجين، فلا يكون قد جمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته (١).

٦. الزوجة الملعنة:

ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه يحرم على الرجل المسلم أن يتزوج زوجته التي لاعنها، وفرق القاضي بينهما، ما دام مصرا على اتهامه لها (٢).

٧. زواج المرأة المرتدة:

وهي من رجعت عن دين الإسلام قصدا واختيارا دون إكراه على تركه، ولا تقر على الدين الذي اعتنقته، ولو كان ديناً سماوياً، ويرى الحنفية أنه لا يجوز نكاح المرتدة لا بمسلم ولا بكافر غير مرتد ومرتد مثله؛ لأن المرتدة تركت الإسلام.

ويرى المالكية عدم جواز نكاح المرتدة، كما قالوا بفسخ النكاح إذا ارتد أحد الزوجين ويكون الفسخ بطلقة بائنة، وإن رجعت المرتدة إلى الإسلام.

وأما الشافعية فقالوا: إن المرتدة لا تحل لأحد، لا لمسلم؛ لأنها كافرة لا تقر، ولا لكافر أصلي لبقاء علاقة الإسلام (٣).

(١) بدائع الصنائع ٢ / ٢٦٢، الدر المختار ٢ / ٣٩١ مغني المحتاج ٣ / ١٨٠، الباب ٦/٣،

المهذب ٢ / ٤٣، بداية المجتهد ٢ / ٤٢، المغني ٦ / ٥٧٤، كشف القناع ٥ / ٨٠.

(٢) نيل الأوطار ٤ / ٢٩١.

(٣) مغني المحتاج ٣ / ١٨٠، الباب ٦/٣، المهذب ٢ / ٤٣، بداية المجتهد ٢ / ٤٢،

المغني ٦ / ٥٧٤، كشف القناع ٥ / ٨٠.

المطلب الرابع

الشهود، وما يجب توافره فيهم من شروط

الشهود ركن في عقد الزواج عند فقهاء الشافعية ، وشروط عند غيرهم، وعلى أي حال، فلا يصح عقد الزواج بدون الشهود باتفاق الفقهاء، وقد اشترط الفقهاء في شهود عقد الزواج عدة شروط ، وبينها كما يلي:

الشروط الأولى: أن يكون الشاهد عاقلًا:

فلا تصح شهادة المجنون على عقد الزواج ، إذ لا تتحقق الغاية والهدف من الشهادة ، وهي الإعلان ، وإثبات عقد الزواج في المستقبل عند الجود والإنكار .

وذكر الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء منهم ابن المنذر حيث قال : " وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه ^(١) .

الشروط الثانية: أن يكون الشاهد بالغًا:

فلا تصح شهادة الصبي حتى ولو كان مميزًا، لأنه لا يتحقق بحضور الصبيان الغرض من الإعلان والتكريم ، ولا يتناسب حضورهم مع خطورة وأهمية عقد الزواج من بين العقود، قال -رحمته- : {وَأَمْسَيْتُهَا سَهْلَيْنِ مِنْ رَجَائِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢].

(١) بدائع الصنائع ٦/٢١٦، الدر المختار ٤/٣٨٥، المغني ٩/٥٨، الإجماع لابن المنذر ٦٧/١.

والصبي ليس من الرجال لقوله - ﷺ -: (رفع العلم عن المرأة: عن التأنيم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يغفل أو يُفقد) ^(١).

وهذان الشرطان متفق عليهما بين الفقهاء، ويمكن جمعها بشرط واحد، وهو كون الشاهدين مكلفين، واختلفوا في شروط أخرى بحسب المقصود من الشهادة، أحو الإعلان فقط كما قال الحنفية؟ أم صيانة العقد من الجور والإنكار كما قال الشافعية؟ ^(٢).

الشرط الثالث: التعدد:

والتعدد شرط باتفاق الفقهاء، فلا ينعقد النكاح بشاهد واحد ^(٣).
لقوله - ﷺ -: (وَأَشْهَدُوا نَوْيَ عَذِيٍّ مِنْكُمْ) [الطلاق: ٢]، وقوله - ﷺ -: (وَأَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) [البقرة: ٢٨٢].

(١) حديث: "رفع العلم عن ثلاثة". أخرجه ابن ماجه (١ / ١٥٨ - ط الحلي) والحاكم (٢ / ٥٩ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عائشة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

(٢) فتح القدير ٦ / ٢٧، الفخاوي الهندية ٣ / ٤٦٤، تبصرة الحكام ٢ / ٧، الخراساني ٧ / ١٩٦، أقرب المسالك ١٧٦، التاج والإكليل ٦ / ١٥٤، مواهب الجليل للحطاب ٦ / ١٥٤، روضة الطالبين ١١ / ٢٤٥، شرح منتهى الإرادات ٣ / ٥٤٥ القوانين الفقهية (٢٠٢)، الإنصاف ١٢ / ٣٧.

(٣) البحر الرائق ٧ / ١٠٢، ١٠٤، المبسوط ١٦ / ١٣٣، أقرب المسالك ١٧٦، التاج والإكليل ٦ / ١٥٤، مواهب الجليل للحطاب ٦ / ١٥٤، روضة الطالبين ١١ / ٢٤٥، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٥٤٥.

حيث دلت الأيتان على وجوب تعدد الشهود في العقود ، ومنها

عقد الزواج .

ولقوله - **ع** - : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » ^(١) .

الشروط الأربع: أن يكون الشهود ذكورا :

لقوله - **ع** - : « وإن شهودوا شهيدين من رجالكم » { البقرة: ٢٨٢ .

والذكورة شرط عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية ، بأن يكون

الشاهدان رجلين ، فلا يصح الزواج بشهادة النساء وحدهن ولا بشهادة

رجل وامرأتين ، لخطورة الزواج وأهميته ، بخلاف الشهادة في الأموال

والمعاملات المالية .

قال الزهري: « مضت السنة ألا تجوز شهادة النساء في الحدود،

ولا في النكاح، ولا في الطلاق » ^(٢) .

ولأنه عقد ليس بمال ، ولا يقصد منه المال ، ويحضره الرجال في

غالب الأحوال ، فلا يثبت بشهادة النساء كالحدود.

وقال فقهاء الحنفية: تجوز شهادة رجل وامرأتين في عقد

الزواج، كالشهادة في الأموال؛ لأن المرأة أهل لتحمل الشهادة وأدائها،

^(١) منن الدار قطني ٢/٢٢٥، كتاب النكاح، منن البيهقي ٧/١٢٥، كتاب النكاح؛

باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين.

^(٢) المبسوط ١٦ / ١٤٣ ، ١٤٤ ، البدائع ١ / ٣٠٢ ، مجمع الأنهر ٢ / ١٨٧ .

وإنما لم تقبل شهادتها في الحدود والفصاص فالشبهة فيها بسبب احتمال النسيان والغفلة وعدم التثبت، والحدود تدرأ بالشبهات^(١).

الشرط الخامس: أن يكون الشهود مسلمين:

لقوله - **يُؤْتَى** -: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١]، والسبيل هو الولاية.

ولأن الشهادة ولاية، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم، فلا تقبل شهادته عليه.

والإسلام شرط باتفاق الفقهاء، بأن يكون الشاهدان مسلمين يقيناً، ولا يكفي مستور الإسلام، واشترطه إذا كان الزوجان مسلمين.

واكتفى الحنفية بهذا الشرط إذا كانت الزوجة مسلمة؛ فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين صح عندهم؛ لأن شهادة الكتابي على مثله جائزة، ولا يصح عند غيرهم؛ لأن الزوج مسلم، ولا بد من معرفة الزواج في أوساط المسلمين^(٢).

(١) الشرح الكبير ٢ / ٢٢٠، الشرح الصغير والصاوي ٢ / ٣٣٥، مبدل السلام ٤

/ ٥٣، كشف القناع ٣ / ٧٢، المغني لابن قدامة ٨ / ٣٩٦.

(٢) المبسوط ١٦ / ١٤٣، ١٤٤، البدائع ١ / ٣٠٢، مجمع الأنهر ٢ / ١٨٧،

مبدل السلام ٤ / ٥٣، كشف القناع ٣ / ٧٢، المغني لابن قدامة ٨ / ٣٩٦.



والحكمة في اشتراط إسلام الشهود في نكاح المسلمين:

أن لهذا المقد خطورة واعتباراً دينياً، فلا بد من أن يشهده مسلم.
ليشتر خبره بين المسلمين. ولما إن كان الزوجان غير مسلمين، فليس
شهادة الكافرين عند الحنفية^(١).

الشرط السادس: أن يكون الشهود مبصرين:

لقوله - ﷺ -: (لَيْسَ الْخَيْرُ كَالْمُعَاتِيَةِ)^(٢).

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط البصر في شاهدي عقد النكاح:
فاشتراط الشافعية في شاهدي النكاح البصر .

واحتجوا لذلك:

بأن الأقوال - وهي المشهود عليه في عقد النكاح - لا تثبت إلا
بالمعاينة والسماع .

بينما لم يشترط الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، وهو وجه عند
الشافعية في شاهدي النكاح البصر ، بل يجوز أن يكونا صريحين إذا
تقنا الصوت تقنا لا شك فيه ، كالشهادة بالاستفاضة .

وحجتهم في ذلك:

أن المعنى - كما يقول الكاساني - لا يقدر إلا في الأداء لتعذر
التمييز بين المشهود عليه وبين المشهود له ، ولأنه لا يقدر في ولاية

^(١) الفتاوى الإسلامية وأدلته للرحلي ٦/١٨٨.

^(٢) قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ، تعليق
للذهبي في التلخيص : على شرط البخاري ومسلم . المستدرک على
المحجین ٢/٣٥١ .

الإنكاح ولا في قبول النكاح بنفسه ولا في المنع من جوار النسوة بشهادته في الجملة ، فكان من أهل أن يعتقد النكاح بحضور . ونقل الشريفي الخطيب عن البحر أن الوجه بالمعنى النكاح بحضور الأعمى حكى عن النص ، لأن الأعمى أهل للشهادة^(١) . والبصر شرط عند الشافعية في الأصح ، فلا تقبل شهادة الأعمى ؛ لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعانة كالسماع ، وهو لا يقدر على التمييز بين المدعي والمدعي عليه . وليس البصر بشرط عند الجمهور ، فتصح شهادة الأعمى إذا سمع كلام العاقلين وميز صوتيهما على وجه لا يشك فيهما ؛ لأنه أهل للشهادة ، وهذه شهادة على قول ، فتصح كما تصح في المعاملات^(٢) .

الشرط السامع : سماع الشهود كالأمر العاقلين ونحوه المراد منه :

شرط عند أكثر الفقهاء ، فلا يعتقد بشهادة نائمين أو أصميين ؛ لأن الغرض من الشهادة لا يتحقق بأمثالهما .

كذلك لا يصح بشهادة المسكران الذي لا يعي ما يسمع ولا يتذكره بعد الصحو .

(١) البدائع الصنائع ٣ / ٢٥٥ ، مفتي المحتاج ٣ / ١٤٤ ، حاشية النسوقي ٤ / ١٦٧ ، كشاف القناع ٥ / ٦٦ .

(٢) المبسوط ١٦ / ١٣٣ ، الشرح الكبير ٢ / ٢٢٠ ، الشرح الصغير والصارى ٢ / ٣٣٥ ، سبل السلام ٤ / ٥٣ ، كشاف القناع ٣ / ٧٢ ، المفتي لابن قدامة ٨ / ٣٩٦ .

ولا يصح أيضاً بشهادة غير عربي في عقد بالعربية إذا كان لا يعرف اللغة العربية ؛ لأن القصد من الشهادة فهم كلام العاقدين، ولذا الشهادة عند اللزوم والاختلاف. (وهذا هو المذهب الراجح عند الحنفية). هذا؛ ولا يشترط في الشهود أن يكونوا ممن لا ترد شهادتهم للزوجين في القضاء:

فيصح الزواج بشهادة ابني الزوجين أو ابني أحدهما إلا عند الحنابلة فلا يصح .

كما يصح بشهادة عدويهما؛ لأن الولد والعدو من أهل الشهادة. ويصح أيضاً بشهادة الحواشي والأعمام إذا كان الولي عند غير الحنفية غيرهم، فالولي عند الجمهور شرط كالشهود، والشهود غير الولي^(١).

وقد وضع الحنفية ضابطاً لمن تقبل شهادته في الزواج ومن لا تقبل، فقالوا:

إن كل من صلح أن يكون ولياً في النكاح بولاية نفسه صلح أن يكون شاهداً فيه فخرج المكاتب فإنه وإن ملك تزويج أمته لكنه بولاية مستفادة من جهة المولى لا بولاية نفسه^(٢).

(١) الفقه الإسلامي وأدلته للزحلي ٦٨/٩.

(٢) البدائع الصنائع ٣٥٣/٢، حاشية ابن عابدين ٢٤/٣، البحر الرائق ٩٥/٣.

المطلب الخامس

الولي: حقيقته، وشروطه

الولي ركن في عقد الزواج عند جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية.
والولي: فعيل بمعنى فاعل - من وليه: إذا قام به؛ فهو القائم
بأمر الشخص المتولي شؤونه.
وهو هنا الأب أو الجد العصبي حال فقد الأب، أو غيره من
أقارب المرأة من العصبه (١).
فهو الذي يتولى الإشراف على زواجها، واختيار من يتزوج بها؛
فهو الملاذ والملجأ الحصين للمرأة (٢).

الشروط الواجب توافرها في الولي:

ليس كل ولي صالح لإبرام عقد الزواج، بل لا بد من توافر
شروط خاصة في الولي الذي يتولى عقد الزواج، وقد بين الفقهاء هذه
الشروط المطلوب توافرها فيه.
وهذه الشروط ليست جميعها محل اتفاق الفقهاء؛ بل منها ما هو
متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه.

(١) البدائع ٥ / ١٥٢، حاشية النسوقي ٣ / ٢٩٢، والخرشي ٤ / ٢٠٧،
وشرح الزرقاني ٤ / ٢٦٣، نهاية المحتاج ٤ / ٣٤٥.

(٢) ليس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: قاسم بن عبد الله بن
أبهر علي القانوني الرومي الحنفي ٥١/١، تحقيق: يحيى مراد، ط/ دار
الكتب العلمية، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً: سعدي أبو جيب ١/ ٣٩٠،
ط/ دار الفكر - دمشق - سورية، الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م.

أولاً: الشروط المتفق عليها:

الشرط الأول: أن يكون الولي أهلاً لتولي عقد الزواج:

وكمال أهلية الأداء: بالبلوغ والعقل، فلا ولاية للمجنون ولا للصغير، لأنه لا ولاية لهما على أنفسهما، فلا تكون لهما ولاية على غيرهما، إذ فاقد الشيء لا يعطيه (١).

الشرط الثاني: اتحاد الدين:

فلا ولاية لغير المسلم على المسلم، ولا للمسلم على غير المسلم، أي لا يزوج عند الحنابلة والحنفية كافر مسلمة ولا عكسه .
وقال الشافعية وغيرهم: يزوج الكافر الكافرة، سواء أكان زوج الكافرة كافراً أم مسلماً.

وقال المالكية: يزوج الكافرة الكتابية مسلم.

ولا ولاية للمرتد على أحد مسلم أو كافر (٢)، لقوله - ﷺ -:
{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: ٧١]، وقوله -
ﷺ -: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: ٧٣]، وقوله - ﷺ -:
{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١].

ثانياً: الشروط المختلف فيها:

هناك عدة شروط مختلف في اشتراطها في الولي، وهي إجمالاً:

(١) مختصر الطحاوي ص ١٦٠، بدائع الصنائع ١٥٣/٥، الدر المختار ٥/٤٩٥.

(٢) حاشية الدسوقي ٣/ ٢٩٢، الخرشي ٤/ ٢٠٧، شرح الزرقاني، ٤/

٢٦٣، نهاية المحتاج ٤/ ٣٤٥.

- (١) العدالة .
- (٢) الذكورة .
- (٣) الرشد .
- (٤) عدم كونه محرماً بحج أو عمرة .
- (٥) الاختيار .

وهاكم هذه الشروط بالتفصيل المناسب:

الشرط الأول: أن يكون الولي عدلاً:

والعدالة تعني: الاستقامة على أمور الدين والأخلاق والمروءات بما يحمل الشخص على عدم ارتكاب الكبائر من الذنوب، وعدم الإصرار على الصغائر، وعدم فعل ما يخل بالمروءة: كالبول في الطرقات، والمشي حافياً، وغير ذلك.

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة في الولي على

قولين:

القول الأول: لا يشترط العدالة في الولي - وهو رأي الحنفية

والمالكية على المشهور ، ووجهه عند الشافعية ، ورواية عن أحمد - (١) .

(١) بدائع الصنائع ٢ / ٢٣٩ ، حاشية ابن عابدين ٢ / ٣١٢ ، فتح القدير ٣ / ١٨٠ ، الشرح الصغير ٢ / ٣٦٩ ، الإنصاف ٨ / ٧٣ ، ٧٤ ، عقد الجواهر الثمينة ٢ / ٢٤ ، مغني المحتاج ٣ / ١٥٥ .

أدلتهم:

استدل أصحاب هذا القول على عدم اشتراط العدالة في الولي
بالكتاب، والسنة، والمعقول:
أولاً: من الكتاب:

استدلوا بعموم قوله -ﷺ-: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: ٣٢]
من غير تفرقة بين عدل وغيره ، ولو كانت العدالة شرطاً في الولي
لذكرت في الآية الكريمة .

ثانياً: من السنة النبوية:

استدلوا بعموم قول النبي -ﷺ-: ﴿ تَخَيَّرُوا لِنَفْسِكُمْ ، وَأَنْكِحُوا
الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ ﴾^(١) . من غير تفرقة بين عدل وغيره .
ثالثاً : من المعقول:

(١) أن الناس عن آخرهم عامهم وخاصهم من لدن رسول
الله -ﷺ- إلى يومنا هذا يزوجون بناتهم من غير
تكثير من أحد^(٢) .

(٢) أن هذه ولاية نظر، والفسق لا يقدح في القدرة على
تحصيل النظر ، ولا في الداعي إليه وهو الشفقة،

(١) أخرجه ابن ماجه ٦٣٣/١، كتاب النكاح: باب الأكفاء، حديث ١٩٦٨،

والدارقطني في سننه ٢٩٩/٣، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ١٩٨.

(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ٣١٢ ، فتح القدير ٣ / ١٨٠ ، الشرح الصغير ٢ /

٣٦٩ ، الإنصاف ٨ / ٧٣ ، ٧٤ ، عقد الجواهر الثمينة ٢ / ٢٤ ، مغني

المحتاج ٢ / ١٥٥ .

وكذا لا يقدح في الولاية ، فلا يقدح في الولاية كالعَدْل .

(٣) أن الفاسق من أهل الولاية على نفسه ، فيكون من أهل الولاية على غيره كالعَدْل ؛ ولهذا قبلنا شهادته ، ولأنه من أهل أحد نوعي الولاية ، وهو ولاية الملك حتى يزوج أمته ، فيكون من أهل النوع الآخر (١) .

القول الثاني: يرى أصحابه أنه يشترط العدالة في ولاية

الذَكَام - وهو رأي الشافعية في المذهب ، والحنابلة كذلك ، وغير المشهور عند المالكية - (٢) .

وعليه ؛ فلا يُزَوَّج الفاسق مؤمنة ، بل ينتقل حق تزويجها إلى الولي الذي يليه ، إن كان عدلاً .

وقد استدلل أصحاب هذا القول على اشتراط العدالة في الولي بالسنة ، والمعقول :

(١) المراجع السابقة .

(٢) الشرح الصغير ٢ / ٣٦٩ ، روضة الطالبين ٧ / ٦٢ ، مغني المحتاج ٣ /

١٥٤ ، الإنصاف ٨ / ٧٣ ، مطالب أولي النهى ٥ / ٦٥ ، وعقد الجواهر

الشمسية ٢ / ٢٤ ، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - د/

مصطفى الخن، د/ مصطفى البغا، علي الشرنجي ٤ / ٦٤ ط/ دار القلم -

تمشق للطبعة: الرابعة، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.

أولاً: من السنة:

قول النبي - ﷺ -: (لا نكاح إلا بولي مُرْتَدٍّ) - رواه الشافعي

في معناه بهذا صحيح .

وقال الشافعي - ﷻ -: المراد بالمرتد في الحديث: العدل .

ثانياً: الدليل من المعقول:

أن الفسق نقص يقدح في الشهادة، فيمنع الولاية في الزواج.

والذي نميل إليه:

عدم اشتراط العدالة في الولي ؛ لأن اشتراط العدالة قد يؤدي إلى حرج كبير لقلة العدل، ولا سيما في هذه الأيام، ولم يعرف أن الفسقة كانوا يُمنعون من تزويج بناتهم في أي عصر من العصور .

كما أن الولاية في الزواج مبنية على وفرة الشفقة على تحريم مصلحة موليته، وهذه الشفقة لا تختلف بين العدل وغيره ^(١).

الشرط الثاني: أن يكون الولي ذكراً:

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط كون الولي في عقد النكاح

ذكراً على قولين :

القول الأول: يشترط في الولي ا الذي يـ تولى بها شقة قد

النكاح المذكورة .

(١) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - ﷻ -: د/ مصطفى الخنف، د/

مصطفى البغا، علي الشرنجي ٤ / ٦٤ ط/ دار الفلم - دمشق الطبعة: الرابعة،

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.

فلا يصح عقد النكاح من أنثى، وأن المرأة لا تملك تزويج نفسها. ولا غيرها بكرة كانت أو ثيباً، شريفة أو دنيسة، رشيدة أو سفينة، حرة أو أمة - وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة - (١).

وفصل الشافعية فقالوا:

لا تزوج المرأة نفسها بآذن من وليها ولا دون إذن منه، ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة عن الولي، ولا تقبل نكاحاً لأحد، قطعاً لها عن هذا الباب، إذا لا يلىق بهما من العادات دخولها فيه، لما قصد منها من الحياء ..

أدلتهم:

استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه من اشتراط الذكورة في الولي الذي يباشر عقد النكاح، وعدم صحة تولي المرأة لعقد النكاح بالكتاب، والسنة، والمعقول:

أولاً: دليل الكتاب:

قول الحق - ﷻ -: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: ٣٤].

وجه الاستدلال:

قال الطبري: معنى {قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}: قيامهم بمصالحهن ومنها ولاية تزويجهن (٢).

(١) الغرشي ٣ / ١٧٢، الشرح الصغير ٢ / ٣٦٩، روضة الطالبين ٧ / ١٧، مفتي المحتاج ٣ / ١٤٧، الإنصاف ٨ / ٦٨، مفتي الإرادات ٣ / ١٦.

(٢) روضة الطالبين ٧ / ٦٧، مفتي المحتاج ٣ / ١٠٦، والغبيري ٣ / ٢٢١.

ثانياً: دليل السنة:

(١) قول النبي - ﷺ -: ﴿ لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزُوجِ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الرِّائِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزُوجُ نَفْسَهَا ﴾ ^(١).

وجه الاستدلال من الحديث:

أن النبي - ﷺ - نهى أن تتولى المرأة عقد النكاح مطلقاً سواء كان هذا العقد لنفسها أو لغيرها، ولنهى يقضي فساد المنهي عنه .

قول النبي - ﷺ -: ﴿ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدِي ﴾ (٢)

عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ^(٣).

وجه الاستدلال من الحديث:

أن تكبير الولي فيه دليل على ذكوره .

فإن قيل: أنه أراد التغليب .

أجيب: بأن ذلك مدفوع بحديث : ﴿ لَا تَزُوجِ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزُوجِ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الرِّائِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزُوجُ نَفْسَهَا ﴾ ^(٤) .

(٣) ما روى عن الحسن قال : حدثني معقل بن يسار أنه نزل فيه قوله

- ﷺ -: ﴿ لَوْ إِذَا طَلَّ طُلُمُ النِّسَاءِ فَبَلَغُنَّ أَجَاهُنَّ فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَّ

(١) نيل الأوطار - الشوكاني ١٧٨/٦.

(٢) أخرجه البيهقي وابن حبان والطبراني في الأوسط عن عمران بن حصين وعائشة وأبي هريرة وحابر وغيرهم، وذكر السيوطي تصحيحه (الجامع الصغير: ٢٠٤/٢، نصب الرية: ١٦٧/٣، مجمع الزوائد: ٢٨٦/٤).

(٣) نيل الأوطار - الشوكاني ١٧٨/٦.

أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٢] قال : زوجت أحدا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء بخطبها فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمك فطلقتها ثم جئت بخطبها لا والله لا تعود إليها أبدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية: {فَلَا تَغْضُوهُنَّ} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله . قال: فزوجنها إياه^(١).

قال الحافظ في الفتح : ومن أقوى الحجج هذا السبب المذكور في نزول هذه الآية المذكورة، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى - العضل : هو أن يمنعها وليها من الزواج وهو من معني التضييق والتعسير - .

ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها ، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه .

ثالثاً: دليل المعقول:

أن جانب المرأة جانب ضعيف مطموع فيه معصوم من الامتهان فلا يليق تركها تتولى مثل هذا الأمر بنفسها لأنه يناقض نفاستها وضعفها فقد يستخف بحقوقها الرجال حرصا على منافعهم وهي تضعف عن المعارضة.

يقول ابن تيمية مؤكداً اشتراط الذكورة في الولي الذي يباشر عقد النكاح، وعدم صحة تولي المرأة لعقد النكاح:

^(١) مسنده طبري المصحيح: ١٩٠/٢ حديث ٢٧١٩.



'دل القرآن في غير موضع، والسنة في غير موضع، وهو عبارة الصحابة، إنما كان يزوج النساء الرجال، لا يعرف عن امرأة شارج نفسها، وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أختان؛ ولهذا قالت عائشة - رضي الله عنها - : لا تزوج المرأة نفسها؛ فإن النبي هي التي تزوج نفسها (١).

القول الثاني: أنه تعم ولاية المرأة.

فعبارة النساء معتبرة في النكاح حتى لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جاز، وكذلك لو زوجت غيرها بالولاية أو الوكالة، وكذا إذا وكلت غيرها في تزويجها أو زوجها غيرها فأجازت - وهو قول أبي حنيفة، وزفر والحسن، وأبي يوسف - (٢).

أدلتهم:

استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه من عدم اشتراط الذكورة في الولي الذي يباشر عقد النكاح، وصحة تولي المرأة لعقد النكاح لنفسها أو غيرها بالكتاب، والسنة، والمعتول:

أولاً: دليل الكتاب:

- (١) قول الحق - ﷻ -: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَكْبِرَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠].
- (٢) قوله - ﷻ -: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْتَصِمْنَ أَنْ يَتَّخِذَنَّ أَرَوَاجَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢].

(١) الشافعي ٢١١٣٢.

(٢) الاختيار لتعيل المختار ٣ / ٩٠.

(٢) قوله - ﷺ -: {إِذَا بَلَغَ الْبُيُوتُ فَلَا خُجَاةَ عَلَيْهِمْ، بَلَا
فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ بِالْمُغْرُوبِ} [البقرة: ٢٣٤].

وجه الاستدلال من الآيات الكريمات:

أن الحق - ﷺ - قد أسند عقد النكاح وأضافه إلى المرأة في هذه
الآيات الكريمات، فكانت هذه الآيات صريحة في أن عقد زواج المرأة
يصل عنها؛ لأن الإضافة تفيد الاختصاص .

ثانياً: الدليل من السنة:

(١) ما روى عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : قال النبي - ﷺ -:
{الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإنها
سكوتها} (١).

وجه الدلالة:

أن هذا الحديث يدل على أن للمرأة البالغة الحق في تزويج
نفسها، وأنها أحق بذلك من وليها فجاز لها أن تتولى عقد الزواج .
مناقشة هذا الدليل:

أنه لا يسلم لهم الاستدلال بهذا الحديث الشريف على عدم

اشتراط الولي لأمرين:

الأمر الأول: أن غاية ما يدل عليه الحديث أن الولي حقا في
تزوج الثيب، وللثيب حق تزويج نفسها ، وحقا أرجح من حقها ، فلم
يجز تزويجها بدون استئمرها، وموافقها أما البكر فحق الولي أعظم من

(١) أخرجه مسلم (٢ / ١٠٢٧ - ط الحطبي) من حديث ابن عباس .

حتمًا، ولذا اكتفى بصمتها، وهذا كله حاله الإجمار، فلا يجوز للولي أن يجبر الأيم على ما تكره.

الأمر الثاني: أنه لو كان معنى الحديث ما أريدوا للزيم أفضلية الزواج بدون الولي، وهذا مخالف ما عليه الحنفية من استحباب رجوع الولي.

(٢) قول النبي - ﷺ -: (لا تنكح الأيم) (التي فارقت زوجها

بطلاق أو موت) حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إزنها؟ قال: أن تسكت^(١). وفي رواية: (ليس للولي من الثيب أمر)^(٢)

وجه الدلالة:

أن الحديث صريح في جعل الحق للمرأة الثيب في زواجها، والبكر مثلها، ولكن نظرًا لغلبة حياتها اكتفى الشرع باستئذانها بما يدل على رضاها، وليس معناه سلب حق مباشرتها العقد، بما لها من الأهلية العامة.

(١) حديث: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح ... " أخرجه البخاري (الفتح ١٩١ / ٩ - ط السلفية)

(٢) أخرجه أبو داود ٢ / ٥٧٩ ودارقطني ٣ / ٢٣٩ وأعله الدارقطني بمخالفة أحد روايته مثلاً، ورواها لمن اشترك معه في الرواية عن شيخه صالح بن كيسان فإسقط الصحيح له هو ما أخرجه مسلم: " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن من نفسها وإنها صامتة " صحيح مسلم (٢ / ١٠٣٧ ط الحلي) .

(٣) عن عبد الله بن بريدة « عن عائشة - رضي الله عنها - أن فتاة دخلت عليها فقالت : إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة : قالت : احلسي حتى يأتي رسول الله - ﷺ - فجاء رسول الله - ﷺ - فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه . فجعل الأمر إليها ، فقالت : يا رسول الله ، قد أجزت ما صنع أبي ، ولكن أردت أن أعلم الناس : أن ليس للآباء من الأمر شيء » (١).

مناقشة هذا الدليل:

أن هذا الحديث ليس بصحيح، فقد رواه البيهقي وقال عنه : " وهذا مرسل ابن بريدة لم يسمع من عائشة - رضي الله عنها . " ورواه الدارقطني وقال عنه : " مرسل ؛ لأن ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئاً، ووافقه على ذلك شمس الحق العظيم آبادي في (التعليق المغني على الدارقطني) وقال : " وإن صح فإنما جعل الأمر إليها لوضعها في غير كفاء . " ولهذا لا يصلح هذا الحديث دليلاً لمذهب الحنفية في صحة تولي المرأة عقد الزواج .

ثالثاً: الدليل من المعقول،

أن للمرأة البالغة العاقلة أهلية كاملة في ممارسة جميع التصرفات المالية من بيع وإيجار ورهن وغيرها، فتكون أهلاً لمباشرة زواجها بنفسها، لأن التصرف حق خالص لها.

الشرط الثالث: أن يكون الولي رشيداً (غير سفيه):

اختلف الفقهاء في اشتراط كون الولي، ففيه قد اختلف كما رشيداً على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط الرشيد في ولاية النكاح - وهو قول الحنفية، والمالكية - .

لكن يستحب عند المالكية أن يكون الترويج من السفه ذي الرأي بائن موليته، وبائن وليه (استحباً لا شرطاً)، فإن زوج ابنته مثلاً يغير إذن وليه، ندب أن ينظر الولي لما فيه المصلحة، فإن كان صواباً أبقاه ولا رده، فإن لم ينظر فهو ماض .

وجبتهم في ذلك:

أن رشد كل مقام بحسبه، والرشد هنا في باب النكاح هو معرفة الكفاءة ومصالح النكاح، وليس هو حفظ المال ، ومن ثم فلا تنزل الولاية في باب النكاح بالسفه الذي هو التبذير بالمال ^(١).

(١) إبدائع الصنائع ٧ / ١٧١، الشرح الصغير ٢ / ٣٦٩، مغني المحتاج ٢ / ١٥٤، الإيضاح ٨ / ٧٥.

القول الثاني: أنه لا ولاية لمجور عليه بسفه بان سلف غير
رشيده أو بذر في ماله بعد رشده ثم حجر عليه - وهو قول الشافعي
على المذهب -.

وحجتهم في ذلك:

أن السفه لا ولاية له على نفسه، فأولى أن لا يكون له ولاية
على غيره (١).

الشرط الرابع: ألا يكون الولي محرماً بجماع أو عمة:

**اختلف الفقهاء في اشتراط خلو ولي النكاح من الإحرام به جم
أو عمة على قولين:**

القول الأول: يرى أنه يشترط في الولي خلوه من الإحرام
بجم أو عمة - وهو رأي المالكية، والشافعية، والحنبلة -.

فالمحرم بأحدهما (الحج، أو العمة) لا يصح منه تولي عقد
النكاح، فمتى تزوج المحرم أو زوج، أو زُوجت محرمة، فالنكاح باطل؛
لأنه منهي عنه، فإن عقد فسخ أبداً .

وإن أحرَم الإمام الأعظم لم يجز أن يتزوج لنفسه ولا لغيره بالولاية
العامة ولا الخاصة لعموم ما سبق ولا أن يزوج أقاربه بالولاية الخاصة ولا
أن يزوج غيرهم ممن لا ولي له بالولاية العامة كالخاصة.

قال النووي : قال الأصحاب: هذه الرواية غير ثابتة، وبها
ابن الرفعة، والظاهر أن الذي زادها من المقهاء أخذها استنباطاً من قول
أبان بن عثمان لما امتنع من حضور العقد فليأمل. (١)

أدلتهم:

استدل أصحاب هذا القول بالسنة والمعقول:

أولاً: الدليل من السنة:

ما روي عن عثمان - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (لَا يَنْكِحُ
الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ) (٢).

ثانياً: الدليل من المعقول:

أن الإحرام يحرم الطيب، فيحرم النكاح كالعدة (فإنها تحرم
الطيب).

القول الثاني: أنه لا بأس للمحرم أن ينكح، وينكح،
وينكح، ولكنه إن تزوج فلا ينبغي له أن يدخل مدته حل - وهو
قول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد -

دليلهم:

استدلوا بما ورد عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - : (تزوج النبي -
صلى الله عليه وسلم - ميمونة بنت الحارث وهو محرم) (٣).

(١) الأئمة والنظائر للسيوطي ص ٢٠٢ ، المنشور للزركشي ١ / ١٨٨ ، الشرح الصغير
٢ / ٣٧٠ .

(٢) أخرجه مسلم ٢ / ١٠٢ . كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المحرم، وكراهية خطبه،
حيث ١٤٠٩/٤١ .

(٣) حديث : (تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم) . أخرجه البخاري (فتح الباري
٧ / ٥٠٩ ط السلفية)

وربه الجمهور على هذا الدليل بما يلي:

(١)

أن هذا الحديث معارض بحديث مسنده .
- **تزوجها حلالاً**، وليس بها حلالاً، ومثله
بصرف - موضع من مكة على عشرة أميال .
أقل أو أكثر - في الظلة التي بنى بها فيها (١)
أنه معارض أيضاً بحديث أبي رافع - **هـ** - قال:
وتزوج رسول الله - **هـ - ميمونة وهو حلال، وليس**
بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما (٢).

(٢)

وميمونة، وأبو رافع أعلم بذاك من ابن عباس، وأولى بالتقديم لو
كان ابن عباس كبيراً، فكيف وقد كان صغيراً لا يعرف حقائق الأمور،
ولا يقف عليها .

وقد أنكر عليه هذا القول؛ قال سعيد بن المسيب: «وهم ابن

عباس، ما تزوجها النبي - **هـ** - إلا حلالاً» .

أن حديث **لا ينكح المحرم...** (٣) قول، فيقدم

(٣)

على الفعل المروي عن ابن عباس، وهو أكد، لأن
الفعل يحتمل أن يكون مختصاً بما فعله - **هـ** - .

(١) سنن الترمذي: ٢٠٣/٣، حديث ٨٤٥، صحيح ابن حبان ٤٤٢/٩، حديث ٤١٣٤.
(٢) الفرجه للترمذي: ٢٠٠/٣، كتاب الحج: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم حديث
٨٤١، وادركه فطحي، ٢٦٢/٣، كتاب النكاح: باب للمهر، حديث ٦٧، ٦٨.

(٣) سبق تفرجه .

الترجيح

الحق؛ رجحان الرأي الأول، لورود رواية أخرى من طرق شتى عن ميمونة نفسها: ﴿ أن النبي - ﷺ - تزوجها وهو حلال ﴾ (١). فإذا تعارض الخبران رجحت رواية الكثرة، فيكون الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة، وحديث عثمان صحيح في منع المحرم، فهو المعتمد. وقد تقول حديث ابن عباس بأن معنى (وهو محرم) أي داخل في الحرم، أو في الأشهر الحرم (٢).

الشرط الخامس: الاختيار:

اختلف الفقهاء في اشتراط أن يكون ولي النكاح غير مكره على عقده على قولين:

القول الأول: يرى أنه لا يصح نكاح الولي الذي أكره على عقد النكاح - وهو رأي المالكية، والشافعية - (٣). وحجتهم: قول النبي - ﷺ -: ﴿ إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ﴾ (٤).

(١) سنن البيهقي الكبرى: ٦٦/٥ حديث ٨٩٤١.

(٢) سبل السلام: ٣/١٤، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٧٢/٩.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٠٣، المنشور للزركشي ١ / ١٨٨، الشرح الصغير ٢ / ٣٧٠.

(٤) حديث: " إن الله وضع عن أمتي . . . " أخرجه ابن ماجه (٦٥٩ / ١) من حديث ابن عباس ، وحسنه النووي في روضة الطالبين (٨ / ١٩٣) .

القول الثاني: يرى أنه يصح نكاح الولي إذا أكره على تزويج موليته - وهو رأي الحنفية - .

وحجتهم في ذلك:

أن النكاح مما لا يحتمل الهزل؛ لقول النبي - ﷺ -: «ثَلَاثُ جِدُّهُمْ جِدٌّ وَهَزْلُهُمْ جِدٌّ: النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ» (١)، والقاعدة عندهم أن كل ما يصح مع الهزل يصح مع الإكراه؛ لأن ما يصح مع الهزل لا يحتمل الفسخ ، وكل ما لا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه (٢).

(١) أخرجه الترمذي التحفة (٤ / ٣٦٢ ط السلفية) وحسنه ابن حجر في التلخيص ٣ / ٢١٠ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة .

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٠٣ ، المنشور للزركشي ١ / ١٨٨ ، الشرح الصغير ٢ / ٣٧٠ .

المبحث الرابع

الآثار الفقهية المترتبة على عقد النكاح الصحيح

يقصد بالآثار المترتبة على عقد الزواج الصحيح: الحقوق التي تترتب على هذا العقد لكلا الطرفين، أو لأحدهما على الآخر، فإذا انعقد الزواج صحيحاً نافذاً لازماً؛ فإن آثاره تترتب عليه في الحال، فيصبح لكل من الزوجين قبل الآخر الحقوق التي رتبها الشارع على عقد الزواج. وهذه الحقوق:

- منها ما هو مشترك بين الزوجين وهو: حل الوطء، وثبوت التوارث بينهما، وثبوت حرمة المصاهرة، وثبوت النسب، وثبوت الإحصان، والمعاشرة بالمعروف.
- ومنها ما هو حق للزوج على زوجته، مثل: حق القرار في البيت، ووجوب الطاعة، وحق التأديب عند النشوز، والطلاق.
- ومنها ما هو حق للزوجة على زوجها، وهو على نوعين:
الأول: حقوق مالية؛ كالمهر، والنفقة، والسكنى .

الثاني: حقوق غير مالية، كالعدل بين الزوجات والمساواة بينهما بالقدر المستطاع - إذا كان الزوج متزوجاً بأكثر من واحدة -، وكالإحسان في المعاملة، وعدم الإضرار بها .

هذا من حيث الإجمال؛ أما على سبيل التفصيل:



أولاً: الحقوق المشتركة بين الزوجين:

(١) حل الوطء، والمعاشرة بين الزوجين:

لقوله -ﷺ-: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: ٥، ٦]؛ فقد نفى الله
-ﷻ- اللوم عمن لا يحفظ فرجه على زوجته فدل ذلك على حل الوطء.
وقوله -ﷻ-: {يَسَاوُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة:
٢٢٣]؛ فالإنسان بسبيل من التصرف في حرثه مع ما قد أباحه الله -
ﷻ- له من إتيان الحرث بقوله -ﷻ-: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.

وروي عن النبي -ﷺ- أنه قال: ﴿انقوا الله في النساء، فإنكم
أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله﴾ (١)، وكلمة الله
المذكورة في كتابه العزيز لفظة الإنكاح والتزويج، فدل الحديث على حل
الاستمتاع بالنساء بلفظة الإنكاح والتزويج، وغيرهما في معاهما، فكان
الحل ثابتاً؛ لذلك .

وهذا الحكم (وهو حل الاستمتاع) مشترك بين الزوجين، فإن
المرأة كما تحل لزوجها، فإن زوجها يحل لها، وللزوج أن يطالبها بالوطء
متى شاء، وللزوجة أن تطالب زوجها بالوطء؛ لأن حله لها حقها كما أن
حلها له حقه .

إلا أن هناك أسباباً طارئة تمنع من حل الوطء مؤقتاً؛ كالحيض
والنفاس والظهار - قبل التكفير - والإحرام وغير ذلك .

^١ صحيح مسلم ٨٨٦/٢ كتاب الحج باب حجة النبي -ﷺ- حديث رقم/ ١٢١٨ .

المبحث الرابع

الآثار الفقهية المترتبة على عقد النكاح الصحيح

يقصد بالآثار المترتبة على عقد الزواج الصحيح: الحقوق التي تترتب على هذا العقد لكلا الطرفين، أو لأحدهما على الآخر، فإذا انعقد الزواج صحيحاً نافذاً لازماً؛ فإن آثاره تترتب عليه في الحال، فيصبح لكل من الزوجين قبل الآخر الحقوق التي رتبها الشارع على عقد الزواج.

وهذه الحقوق:

- منها ما هو مشترك بين الزوجين وهو: حل الوطء، وثبوت التوارث بينهما، وثبوت حرمة المصاهرة، وثبوت النسب، وثبوت الإحصان، والمعاشرة بالمعروف.
- ومنها ما هو حق للزوج على زوجته، مثل: حق القرار في البيت، ووجوب الطاعة، وحق التأديب عند النشوز، والطلاق.
- ومنها ما هو حق للزوجة على زوجها، وهو على نوعين:
 - الأول: حقوق مالية؛ كالمهر، والنفقة، والسكنى .
 - الثاني: حقوق غير مالية، كالعدل بين الزوجات والمساواة بينهما بالقدر المستطاع - إذا كان الزوج متزوجاً بأكثر من واحدة -، وكالإحسان في المعاملة، وعدم الإضرار بها .

هذا من حيث الإجمال؛ أما على سبيل التفصيل:

أولاً: الحقوق المشتركة بين الزوجين:

(١) حل الوطء، والمعاشرة بين الزوجين:

لقله - ﷺ: { وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ • إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } [المؤمنون: ٥، ٦]؛ فقد نفى الله - ﷻ اللوم عمن لا يحفظ فرجه على زوجته فدل ذلك على حل الوطء. وقوله - ﷻ: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْى شِئْتُمْ } [البقرة: ٢٢٣]؛ فالإنسان بسبيل من التصرف في حرثه مع ما قد أباحه الله - ﷻ له من إتيان الحرث بقوله - ﷻ: { فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْى شِئْتُمْ }.

وروي عن النبي - ﷺ - أنه قال: ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ﴾ (١)، وكلمة الله المكورة في كتابه العزيز لفظة الإنكاح والتزويج، فدل الحديث على حل الاستمتاع بالنساء بلفظة الإنكاح والتزويج، وغيرهما في معناهما، فكان الحل ثابتاً؛ لذلك .

وهذا الحكم (وهو حل الاستمتاع) مشترك بين الزوجين، فإن المرأة كما تحل لزوجها، فإن زوجها يحل لها، وللزوج أن يطالبها بالوطء متى شاء، وللزوجة أن تطالب زوجها بالوطء؛ لأن حله لها حقها كما أن حلها له حقه .

إلا أن هناك أسباباً طارئة تمنع من حل الوطء مؤقتاً؛ كالحيض والنفس والظهار - قبل التكفير - والإحرام وغير ذلك .

(١) صحيح مسلم ٨٨٦/٢ كتاب الحج باب حجة النبي - ﷺ - حديث رقم / ١٢١٨ .

ففي مانع الحيض يقول - **الحديث** -: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } [البقرة: ٢٢٢]، والنفاس أخو الحيض .

وفي مانع الظهار قبل التكفير يقول - **الحديث** -: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَمْ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [المجادلة: ٣، ٤].

وفي مانع الإحرام يقول - **الحديث** -: {لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ} (١).
(٢) ثبوت حق الإرث من الجانبين جميعاً .

لقوله - **الحديث** -: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ ذَيْنَ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ } [النساء: ١٢].
(٣) ثبوت حرمة المصاهرة:

فتن بقدرمة المصاهرة تأبيداً، وهن أربع: زوجة الأب، وأم الزوجة، وبنت الزوجة المدخول بها، وزوجة الابن؛ فلا يحل التزوج بهن.

(١) صحيح مسلم ١٠٣٠/٢ كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم حديث رقم /١٤٠٩.

أما تحريم زوجة الأب:

في قوله -ﷺ-: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا فَعَلَ سَلَفُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [النساء: ٢٢].

وأما تحريم أم الزوجة، وبنت الزوجة المدخول بها، وزوجة

الابن:

في قوله -ﷺ-: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: ٢٣].

(٤) ثبوت النسب:

وإن كان ذلك حكم الدخول حقيقة لكن سببه الظاهر هو النكاح؛ لكون الدخول أمراً باطناً، فيقام النكاح مقامه في إثبات النسب؛ ولهذا قال النبي -ﷺ-: (الولد للفراش، وللعاهر الخجر) (١).

(٥) ثبوت الإحصان بالدخول (أي: الوطء) الموجب لإقامة المحد عليهما

بالرجع لو وقعاً في الرثا:

فالإحصان في الشريعة الإسلامية: الوطء الحاصل من المكلف الحر في نكاح صحيح ذكراً كان أو أنثى (٢).

(١) متفق عليه . ينظر: صحيح البخاري ٢٤٨١/٦ كتاب الفرائض باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة حديث رقم/٦٣٦٨، صحيح مسلم ١٠٨٠/٢ كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتوفي الشبهات حديث رقم/١٤٥٧ .

(٢) أسنى المطالب لأبي زكريا الأنصاري ١٢٨/٤، حاشية إعانة الطالبين للبكري النميطي ١٤٦/٤ .

(فالوطء): يقصد به: الوطء في القبل، لا خلاف في اشتراطه؛ لأن النبي - ﷺ - قال: ﴿الثيب بالثيب جلد مائة والرجم﴾^(١)، والثيابة تحصل بالوطء في القبل، فوجب اعتباره .

ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطء لا يحصل به إحصان - سواء حصلت فيه خلوة، أو وطء دون الفرج، أو في الدبر^(٢)، أو لم يحصل شيء من ذلك -؛ لأن هذا لا يصير به المرأة ثيباً، ولا تخرج به عن حد الأبكار، الذين حددهم جلد مائة وتغريب عام، بمقتضى الخبر: ﴿البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة﴾^(٣).

ولا بد من أن يكون وطئاً حصل به تغييب الحشفة أو قدرها عند فقدتها في القبل؛ لأن ذلك حد الوطء الذي يتعلق به أحكام الوطء .

وقولهم: (الحاصل من المكلف الحر):

أي الواقع من البالغ العاقل الحر .
وهو قيد في التعريف يخرج به: الصبي والمجنون والرقيق، فلا يحصل الإحصان لأي منهم بالوطء وهم على هذا الحال .

(١) صحيح مسلم كتاب الحدود باب حد الزنا حديث رقم/ ٤٥٠٩، مسند أحمد باب حديث عبادة بن الصامت - ﷺ - حديث رقم/ ٢٢٧١٨، السنن الكبرى للبيهقي كتاب الحدود باب ما جاء في نفي البكر حديث رقم/ ١٦٧٤٥ .

(٢) حكم الدبر حكم القبل إلا في الإحصان والإحلال - نص عليه الأصحاب - .
ينظر: (النجم الوهاج في شرح المنهاج لأبي البقاء الدميري ٩ / ١١٥) .

(٣) صحيح مسلم كتاب الحدود باب حد الزنا حديث رقم/ ٤٥٠٩، مسند أحمد باب حديث عبادة بن الصامت - ﷺ - حديث رقم/ ٢٢٧١٨ .

وقولهم: (في نكاح):

أي لابد أن يكون هذا الوطء الحاصل من المكلف الحر واقعاً في نكاح؛ لأن النكاح يسمى إحداً صانداً؛ بدليل قول الحق - ﷻ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٤]؛ يعني: المتزوجات.

وهو قيد يخرج: الوطء في ملك اليمين، ووطء الشبهة، والزنا؛ فلا يصير الواطئ بواحد منها محصناً، لكونه ليس بنكاح، ولا تثبت فيه أحكامه.

وتقيدهم النكاح بكونه صحيحاً:

ليخرج به: الوطء في نكاح فاسد^(١)، فلا يحصل به الإحصان؛ لأنه وطء في غير ملك كوطء الشبهة.

(١) النكاح الفاسد: ما اختلف فيه شرط من الشروط المختلف فيها بين أهل العلم المعتبرين، أو هو ما اختلف أهل العلم في فساد، مثل: النكاح بلا ولي، أو بلا شهود، والنكاح بنية الطلاق، ونحو ذلك، فالوطء في مثل هذا العقد لا يوجب الحد لوجود الشبهة، ولكن للقاضي - إذا كان يرى فساد هذا العقد - أن يعزرهما بما يراه مناسباً.

وهو يفترق عن النكاح الباطل الذي هو: ما اختلف فيه شرط من الشروط المجمع عليها، أو هو ما اتفق أهل العلم على بطلانه، مثل نكاح المسلمة للكافر، ونكاح المعتدة، ونكاح الخامسة، ونكاح المحرمات كالعمة وزوجة الابن وأخته من الرضاعة، والجمع بين الأختين ونحو ذلك، فالوطء في مثل هذا العقد يوجب الحد لعدم الشبهة. ينظر: (الحدود: د/ يوسف بن عبد الله الشيبلي ص/ ٦).

وقياس الوطء في النكاح الفاسد على الوطء في الشبهة: أن النكاح الفاسد صار شبهة لإسقاط الحد، فصار الوطء فيه كوطء الشبهة سواء بسواء (١).

هذا ومما ينبغي التأكيد عليه:

أن الإحصان بالوطء في النكاح الصحيح يحصل ولو كان على وجه محرم؛ كما إذا وطأها في حيض أو إحرام أو في نهار رمضان .
والعلة في ذلك:

أن بهذا الوطء قد قضى الواطئ شهوته، واستوفى اللذة، فكان حقه بعد أن استوفى تلك اللذة الكاملة أن يمتنع عن الحرام باجتناب الزنا (٢).

الدليل على ثبوت الإحصان بالإصابة في النكاح:

يدل على ثبوت الإحصان بالإصابة في النكاح:

ما رواه الشيخان البخاري مسلم عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: ﴿ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ﴾ (٣).

(١) النجم الوهاج في شرح المنهاج لأبي البقاء الدميري ٩ / ١١٥، مغني المحتاج

للخطيب الشربيني ٥ / ٤٤٧، المغني لابن قدامة ١٠ / ١١٧.

(٢) نهاية الزين في إرشاد المبتدئين للجاوي ١ / ٣٤٨، مغني المحتاج للخطيب

الشربيني ٥ / ٤٤٧.

(٣) متفق عليه؛ ينظر: (صحيح البخاري كتاب الديات حديث رقم / ٦٤٨٤،

صحيح مسلم كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم حديث رقم / ٤٤٧٠).

ولا خلاف أن المراد بالثيب هنا: الذي وطئ في نكاح صحيح،
فليس المراد بالثيابة: زوال العذرة؛ لعدم هذه الصفة في الرجال . فنعين
أن المراد بها: الوطء .

قال القاضي أبو الطيب:

وقد أجمعوا على أن المراد بالثيوبة: الوطء في النكاح الصحيح .
وإنما اعتبر الإحصان بالوطء في نكاح صحيح؛ لأمر ثلاثة:
الأول: أن النكاح أكمل ما يمنع من الزنا، فكان شرطاً في أكمل
حديثه، ومجرد العقد لا يمنع حتى توجد فيه الإصابة المانعة من غيره؛
حيث إن للوطء مزية تقتضي توقف الإحصان عليه فلا يكفي مجرد
العقد^(١) .

بيان ذلك:

أن البينونة في النكاح تحصل بمجرد الطلاق ولو بطلقة واحدة إذا
طلق زوجته قبل الدخول .
وهذا بخلاف ما إذا وجد الطلاق بعد الدخول؛ فلا تحصل البينونة
بمجرده، بل لا بد من انقضاء العدة .

(١) بدائع الصنائع للكاظمي ٣٨ / ٧، الحاوي الكبير للماوردي ١٣ / ١٩٦، المراج
الوهاج على متن المنهاج للغمراوي ١ / ٥٢٢، كفاية النبيه شرح التنبيه لابن
الرفعة ١٧ / ١٧٢، ١٧٤، أسنى المطالب لأبي زكريا الأنصاري ٤ / ١٢٨ .

فعلم من هذا: أن للوطء مزية تقتضي توقف الإحصان عليه، فلا يكتفى فيه (في الإحصان) بمجرد العقد (١).

الأمر الثاني:

أن الشهوة مركبة في النفس، وبالوطء في نكاح صحيح يكون الواطئ قد قضى الشهوة واستوفى اللذة؛ فحقه أن يمتنع عن الحرام.

الأمر الثالث:

أنه إذا أصاب امرأته فقد أكد استفراشها، وحينئذ فلو لطيخ غيره فراشه عظمت وحشته وأذيته؛ فحقه أن يمتنع عن تلطيخ فراش الغير، فإذا لم يمتنع فقد عظمت جنايته (٢).

(٦) المعاشرة بالمعروف:

قال الله - ﷻ -: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩]، قيل: هي المعاشرة بالفضل والإحسان قولاً وفعلًا وخلقاً .
يدل لذلك قول النبي - ﷺ -: ﴿خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي﴾ (٣).

(١) نهاية الزين في إرشاد المبتدئين للجاوي ١ / ٣٤٨، مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٥ / ٤٤٧، حاشية البجيرمي على الخطيب ٤ / ١٧٣ .

(٢) الحاوي الكبير للماوردي ١٣ / ١٩٥، كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الإمام الشافعي - لابن الرفعة ١٧ / ١٧٣، أسنى المطالب لأبي زكريا الأنصاري ٤ / ١٢٨ .

(٣) الجامع الصحيح للترمذي ٥ / ٧٠٩ كتاب المناقب باب فضل أزواج النبي - ﷺ - حديث رقم / ٣٨٩٥ . قال أبو عيسى الترمذي: * هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري * .

وقيل: المعاشرة بالمعروف: هي أن يعاملها بما لو فعل بك مثل ذلك لم تنكره بل تعرفه، وتقبله وترضى به .

وكذلك من جانبها هي مندوبة إلى المعاشرة الجميلة مع زوجها بالإحسان باللسان، واللفظ في الكلام، والقول المعروف الذي يطيب به نفس الزوج؛ قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٢٨].

ثانياً: حقوق الزوج على زوجته:

(١) ملك الحبس والقيود (القرار في البيت):

وهو صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبروز إلا بإذنه؛ لقوله - ﷺ -: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: ٦]، والأمر بالإسكان نهي عن الخروج، والبروز، والإخراج؛ إذ الأمر بالفعل نهي عن ضده، وقوله - ﷺ -: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: ٣٣]، وقوله - ﷺ -: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: ١]؛ ولأنها لو لم تكن ممنوعة عن الخروج والبروز لاختل السكن والنسب؛ لأن ذلك مما يريب الزوج، ويحمله على نفي النسب .

(٢) وجوب طاعة الزوج في غير معصية:

لقوله - ﷺ -: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٢٨]، قيل: لها المهر والنفقة، وعليها أن تطيعه في نفسها، وتحفظ غيبته .
ولأن الله - ﷻ - أمر بتأديبهن بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن، ونهى عنه عند طاعتهن بقوله - ﷻ -: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا}

عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: ٣٤]، فدل أن التأديب كان لترك الطاعة، فيدل على لزوم طاعتهم الأزواج .

(٣) حق التأديب إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته فيه:

فللزواج في هذه الحالة أن يؤدبها، وقد حدد القرآن الكريم وسائل تأديب الزوجة في قوله -ﷺ-: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعْظَوْهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: ٣٤].

فقد حددت الآية الكريمة طرق تأديب الزوجة الناشز بثلاث

وسائل:

الوسيلة الأولى: الوعظ، وذلك بتذكيرها بما أوجب الله عليها من حسن الصحبة، وجميل العشرة .

الوسيلة الثانية: الهجر في المضاجع، لكن على الترتيب، على خلاف بين الفقهاء في معنى الهجر؛ هل المقصود به ترك الجماع والمضاجعة؟ أو المقصود به ترك الكلام معها في حال المضاجعة؟ لأن المضاجعة حق مشترك بينهما، فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها، فلا يؤدبها بما يضر بنفسه، ويبطل حقه، أو المقصود به مفارقتها في المضجع؟ .

الوسيلة الثالثة: الضرب ضرباً غير مبرح، ولا شائن .

وظاهر الآية وإن كان بحرف الواو الموضوع للجمع المطلق إلا أن المراد منه الجمع على سبيل الترتيب، والواو تحتل ذلك، فإن نفع الوعظ، وإلا انتقل إلى الهجر، وإلا انتقل إلى الضرب .

فإذا استنفذ الزوج هذه الوسائل ولم يتمكن من إصلاح الزوجة، انتقل أمر الإصلاح إلى الحكّمين المعيّنان بقوله -ﷺ-: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: ٣٥].

فإذا لم يوفقا في الإصلاح بينهما رفع الأمر إلى القاضي للتوفيق، أو التفريق؛ {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: ١٣٠].
(٤) الطلاق:

وهو حق الزوج في حالة ما إذا فسد الحال بينه وبين زوجته، وأصبح بقاء النكاح مفسدة محضة، وضرراً مجرداً.
ثالثاً: حقوق الزوجة على زوجها:

(١) وجوب المهر على الزوج:

وهو حكم أصيل للنكاح لا وجود له بدونه شرعاً؛ لأن المهر عوض عن ملك الزوج الاستمتاع بزوجه شرعاً؛ وثبوت العوض يدل على ثبوت المعوض. قال -ﷺ-: {وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: ٢٤].

(٢) وجوب النفقة، والسكنى: يدل لذلك قول الحق -ﷺ-: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٣]، وقوله -ﷺ-: {لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: ٧]، وقوله -ﷺ-: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْهِكُمْ}

[الطلاق: ٦]؛ والأمر بالإسكان أمر بالإتفاق؛ لأنها لا تمكن من الخروج للكسب لكونها عاجزة بأصل الخلقة لضعف بنيتها .

(٣) وجوب العدل بين النساء إذا كان متزوجاً بأكثر من واحدة:

فإن كان للرجل أكثر من امرأة: فعليه العدل بينهما في حقوقهن من القسم والنفقة والكسوة، وهو التسوية بينهما في ذلك، حتى لو كانت تحته امرأتان يجب عليه أن يعدل بينهما في المأكل والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة .

والأصل فيه: قوله -ﷺ-: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: ٣] عقيب قوله -ﷺ-: {فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣].

أي: إن خفتم أن لا تعدلوا في القسم والنفقة في نكاح المثنى، والثلاث، والرابع، فواحدة فالله -ﷻ- قد ندب إلى نكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة، وإنما يخاف على ترك الواجب، فدل أن العدل بينهما في القسم والنفقة واجب، وإليه أشار في آخر الآية بقوله -ﷺ-: {ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا} أي: تجوروا، والجور حرام، فكان العدل واجباً ضرورة؛ ولأن العدل مأمور به لقوله -ﷺ-: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} [النحل: ٩٠] على العموم والإطلاق إلا ما خص أو قيد بدليل . روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: (إذا

كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشفه
ساقط^(١).

هذا؛ وآخر دعوانا:

أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين

(١) المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری ٢/٢٠٣ کتاب النکاح حدیث
رقم/٢٧٥٩. وقال: " هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین و لم یخرجاه " .